

Petição de Embargos de Declaração



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL**

Mandado de Segurança nº 5002479-81.2021.8.08.0021

ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária já devidamente qualificada na petição inicial, por seus advogados constituídos, com elevado respeito à presença de Vossa Excelência, **nos autos da ação de Mandado de Segurança nº 5002479-81.2021.8.08.0021, impetrado em face do Sr. Secretário de Fazenda do Município de Guarapari/ES**, vem opor, com fulcro no art. 994, IV c/c art. 1022, I e II do CPC/2015, à luz da contradição e omissões detectadas, os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

consoante as razões abaixo expostas:

Página 1 de 13

Rua Judith Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477 | www.abreujudice.com.br



I – DA DECISÃO EMBARGADA

01. O presente writ foi ajuizado durante as férias regulares de Vossa Excelência, eminente Magistrado Titular deste honrado juízo, razão pela qual os autos seguiram concluso ao magistrado tabelar, Dr. Marcelo Mattar Coutinho, para o exame do pedido de liminar, tendo sido indeferido o pleito sob o argumento de o pedido de liminar confundir-se com o mérito e, também, por não se ter vislumbrado o requisito fático do periculum in mora, muito embora, quanto à matéria de fundo, tenha observado a relevância do direito alegado.

02. Vejamos a dicção do quanto decidido:

"No caso ora examinado, conquanto seja relevante a fundamentação, não se mostra evidente a presença de requisitos que possibilitem a antecipação da segurança em caráter liminar.

Afinal, a liminar pleiteada está vinculada ao pleito de imediato reconhecimento da imunidade relativa ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI quanto ao imóvel "apartamento nº. 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari", o que se confunde com o próprio mérito do writ e esgota o objeto da impetração, o que recomenda seja apreciado em momento oportuno, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, em prestígio à segurança jurídica e ao contraditório, mormente tendo em conta o rito célere do *mandamus*.

É válido destacar, aliás, que a cobrança do tributo em questão pela municipalidade baseia-se, segundo alega o impetrante, em possível interpretação equivocada da *ratio decidendi* do Recurso Extraordinário n.º 796.376/SC – TEMA 796 – julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, realizada pela Procuradoria do Município, que deu ensejo ao ato supostamente ilegal perpetrado pelo Sr. Secretário da Fazenda do Município de Guarapari, merecendo, portanto, análise mais aprofundada acerca do pleito. Referido panorama, à toda evidência, acentua a necessidade de prévia oitiva da autoridade coatora, para o fim de apreciação da pretensão e melhor compreensão acerca da legalidade - ou não - da cobrança do tributo.

Por fim, cabe ponderar que não há possibilidade de "resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida" (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III), requisito indispensável para a concessão da medida liminar no caso em cotejo.

Nesse particular, cumpre consignar que o critério mais relevante da liminar em sede de mandado de segurança, nos termos de sua especial legislação de regência, não é o prognóstico de sucesso da concessão definitiva, mas sim a irreparabilidade do dano no caso da demora, desde que exista fundamento relevante. A jurisprudência trilha por esse caminho:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR
PARA CONVOCAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO NO
CARGO DE PROFESSOR. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO EM



VIRTUDE DE O REFERIDO CANDIDATO NÃO TER COMPARECIDO PARA TOMAR POSSE PELO FATO DE QUE A INTIMAÇÃO DELE OCORREU EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE DIÁRIO DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração cumulativa da existência de fundamento relevante e de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final deferida, não se concede liminar em mandado de segurança. (TJMS; AgRg 1411448-53.2015.8.12.0000; Primeira Seção Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 19/11/2015; Pág. 6).

Disso não discrepa o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - PRETENSÃO DE CUNHO SATISFATIVO.

1. A determinação de nomeação para o cargo a que foi candidato o impetrante é medida antecipatória do pleito final, confundindo-se com o mérito do mandamus, circunstância que inviabiliza a concessão da liminar no presente caso, dado seu caráter satisfativo. 2. Agravo regimental não provido" (1ª Seção, Processo AgRg no MS 19997 DF 2013/0089880-5, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe 21/06/2013).

À luz do exposto, INDEFIRO a liminar.

Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º).

Prestadas as informações, ou decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Em seguida, com ou sem o parecer do Ministério Público, venham conclusos para decisão.

Diligencie-se.

GUARAPARI-ES, 23 de julho de 2021.

MARCELO MATTAR COUTINHO
Juiz de Direito"

03. Embora a decisão tenha vislumbrado a relevância do direito alegado, o douto magistrado tabelar, em inexorável contradição, identificou uma satisfatividade jurídica



e imediata do pedido final a título de liminar, incompatível, ao seu ver, com a feição do writ, e, como se não bastasse, afastou o periculum in mora, o que, igualmente, configura-se contradição, na medida em que se reconheceu a relevância da fundamentação do direito apontado.

04. Ambas perspectivas, data máxima vênia, estão equivocadas, pelo que a impetrante, com o devido respeito, pretende obter a correção dos vícios detectados e, bem assim, a reconsideração do quanto decidido, a fim de que a medida liminar seja deferida tal qual pleiteada (CTN, art. 151, IV), ou, em última ratio, mediante o depósito do valor da exação para efeito do que dispõe o inciso II, do art. 152, do CTN.

II. DA CONTRACTIO IURIS:

05. A primeira contradição a ser apontada reside nas seguintes asserções constantes da decisão:

“No caso ora examinado, conquanto seja relevante a fundamentação, não se mostra evidente a presença de requisitos que possibilitem a antecipação da segurança em caráter liminar.

“Afinal, a liminar pleiteada está vinculada ao pleito de imediato reconhecimento da imunidade relativa ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (...) o que se confunde com o próprio mérito do writ e esgota o objeto da impetração, o que recomenda seja apreciado em momento oportuno, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, em prestígio à segurança jurídica e ao contraditório, mormente tendo em conta o rito célere do mandamus.”

06. Ora, se o magistrado tabelar afirma que a fundamentação é relevante, está a admitir o que a doutrina denomina de fumus boni juris, devendo-se, então, perquirir sobre o outro requisito periculum in mora, o que foi afastado sob premissas contraditórias.

07. Por sua vez, afirma-se na decisão embargada que o pedido de liminar haveria de ser apreciado em momento oportuno, após as informações. Ocorre que, se assim o fosse, não deveria tê-la indeferido in limine, e, tampouco, ao final, decidir por

Prestadas as informações, ou decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.



Em seguida, com ou sem o parecer do Ministério Público, venham conclusos para decisão.

08. Nessa fase, ao retornar os autos, não há espaço para decisão liminar, senão para sentença a ser prolatada.
09. Em resumo, a decisão denegatória da liminar é uma não-decisão, na medida em que, conquanto se tenha vislumbrado a relevância do direito, a essa circunstância sequer se reportou, como se a concessão da liminar se bastasse, apenas, com o periculum in mora e a não-satisfatividade jurídica imediata.
10. Essa confusão entre o que se deve entender por situação objetiva de perigo iminente a autorizar a tutela de urgência e o que se deve compreender por satisfatividade jurídica e satisfatividade fática, tal como posto pela decisão embargada, demonstram uma verdadeira contradição com o tudo o que foi alegado e documentalmente comprovado com a petição inicial.
11. O ilustre magistrado tabelar ao decidir pelo indeferimento do pedido liminar confundiu o que se deve entender por i) satisfatividade jurídica e ii) satisfatividade fática. A primeira (i) decorre do julgamento de mérito, por ocasião da sentença definitiva, com o reconhecimento e a declaração sobre existência, ou não, da relação jurídico-tributária, ou seja, do direito líquido e certo deduzido, decorrendo daí um comando mandamental (uma ordem), em definitivo, para a autoridade impetrada.
12. Por sua vez, a satisfatividade fática reserva-se a juízos provisórios acerca da relevância do direito pleiteado à luz de uma situação objetiva de perigo iminente, o que se verifica nos estágios do juízo liminares e provisórios.
13. In casu, a relevância do direito deduzido foi reconhecida pela decisão do magistrado tabelar ao, explicitamente, reconhecer como "relevante" a fundamentação esposada pela impetrante. Todavia, cioso de que a concessão da medida liminar pudesse adquirir foros de tutela excessiva e imprópria para a fase inicial, o d.d. magistrado entendeu que havia uma similitude entre a tutela liminar e a tutela definitiva, a ponto de advertir que o pedido de liminar "se confunde com o próprio mérito do writ e esgota o objeto da impetração".



Ledo engano!

14. A tutela liminar em sede de Mandado de Segurança pode ser revestir tanto de i) feição cautelar, quando se assegura o direito sem satisfazê-lo faticamente; ii) quanto de conformação antecipatória de um ou de todos os efeitos do direito pleiteado, satisfazendo, apenas, faticamente. Isso também se verifica nas medidas cautelares e nas antecipações de tutela requeridas e deferidas no âmbito das ações de procedimento comum. Entretanto, ambas tutelas, cautelar e antecipatórias, são possíveis de serem requeridas e deferidas, a título de tutela de urgência, tanto cá, como acolá, sem que se verifique, em abstrato, satisfatividade jurídica, senão apenas fática.

15. A decisão do ilustre magistrado tabelar verificou uma abstrata – e não concreta - impossibilidade jurídica de o pedido liminar antecipar integralmente os efeitos a sentença final, como se fosse algo inusitado e indevido. Mais um ledor engano!

16. A impetrante, diante da natureza da questão debatida, trouxe ao Poder Judiciário a necessidade de se reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária a propósito do ITBI na operação descrita de integralização de capital, em sociedade empresária; ou seja, busca-se o reconhecimento do direito líquido e certo à imunidade constitucional sobre a incidência da mencionada exação.

17. O pedido de mérito tem alta carga declaratória quanto a não-existência de relação jurídico-tributária a partir do reconhecimento do direito líquido e certo à imunidade (não-incidência) tributária e, por conseguinte, carga mandamental (ordem de imperium) dirigida à autoridade impetrada para que não exija o tributo e forneça a competente certidão para fins de propiciar o registro da propriedade em favor da impetrante no CRGI competente.

18. No tocante ao pedido de liminar, em atenção à necessária congruência com o pedido definitivo, pediu-se, em suma, a antecipação do efeito da sentença de mérito de procedência, qual seja, que a autoridade impetrada se abstenha de exigir provisoriamente o recolhimento do tributo. Essa ordem, em nível liminar, é perfeitamente factível e possível, não se confundindo com o pedido de mérito que terá como base uma declaração definitiva sobre a existência, ou não, do direito líquido e certo e da relação jurídico-tributária.

19. Dessa feita, afirma-se, com convicção: o mandamento liminar decorre

Página 6 de 13

Rua Judith Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477 | www.abreujudice.com.br



de um juízo provisório da evidência e relevância do direito, sem todavia esgotar-se em juízo definitivo, tanto que, ao final, não se reconhecendo o direito alegado, uma vez deferida a liminar, a impetrante estará sujeito ao pagamento da exação, sob pena de ser inscrita em dívida ativa e ficar sujeita à execução fiscal, apontamento de protesto etc. Ou seja, o tributo poderá ser cobrado e exigido!

20. Portanto, não há a alegada incongruência entre os pedidos de liminar e de mérito, lançados. Essa situação é, em demasia, comum nas ações mandamentais de cunho tributário e fiscal.

21. O novo CPC/2015 estabelece regras específicas a propósito da tutela provisória que pode ser de tanto de urgência quanto de evidência, cuja disciplina, estabelecida com mais técnica do que o quanto previsto na Lei no 12.016/2009 (art. 7o), é perfeitamente aplicável à ação do mandado de segurança.

22. Portanto, sob o acicate da urgência (*periculum in mora*), a tutela pode ser cautelar ou antecipada, tal qual previsto no parágrafo único do art. 294, CPC/2015. A impetrante não requereu qualquer medida liminar de cunho cautelar, como uma medida assecuratória para futura execução do decisum. Ao contrário, pediu-se a execução imediata dos efeitos da decisão futura, para a segurança do direito, numa visão perfeita da doutrina de Pontes de Miranda, quando traça a dicotomia entre “segurança para futura execução” (cautelar) e “execução imediata para segurança do direito” (antecipação de tutela), medidas díspares e orientadas pela incidência do *periculum in mora*.

23. E, em sendo antecipada a tutela liminar, como sói ocorrer no presente caso sob o rito do mandado de segurança, por certo que poderão ser antecipados, total ou parcialmente, os efeitos da tutela definitiva de mérito. Não há, d.v., nenhuma incongruência ou óbice a impedir a antecipação de todos os efeitos requeridos na tutela final, ou do efeito maior desejado: impedir a exigência tributária de imediato; podendo-se, todavia, impor a exação, ao final, sendo improcedente a pretensão de mérito.

24. Foi o que se requereu no caso *sub judice*, sem que se possa apontar qualquer equívoco petitário, sendo, sim, adequada a tutela liminar requerida para impedir à autoridade impetrada que exija, de imediato, na operação apontada, o ITBI, uma vez não-



incidente.

25. Portanto, a contradição apontada merecer ser reparada.

26. Há, ainda, omissão, senão vejamos:

27. Fundamentos sobejos, sobre a questão, estão minuciosamente expostos na petição inicial, tanto que reconhecidos como “relevantes” pelo d.d. magistrado tabelar.

28. Com todo respeito, a “análise mais aprofundada acerca do pleito” dar-se-á com a disposição de uma atenta leitura do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em específico, do voto do ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do RE no 796.376/SC, Tema 796, sob o regime da repercussão geral.

29. Os fundamentos que embasaram o ato coator já se encontram evidenciados no Parecer subscrito pelo Douto Procurador Municipal, Dr. Arthur Daher Colodetti, integralmente acolhido, sendo suficiente para a análise do pedido liminar o cotejo entre o que ali se sustenta e os fundamentos da petição inicial.

30. Omitiu-se integralmente a decisão embargada quanto aos fundamentos jurídicos da impetração, conquanto, repita-se, tenham sido apontados como “relevantes”.

31. Por sua vez, também se equivoca a decisão do ilustre magistrado tabelar ao sustentar:

“Nesse particular, cumpre consignar que o critério mais relevante da liminar em sede de mandado de segurança, nos termos de sua especial legislação de regência, não é o prognóstico de sucesso da concessão definitiva, mas sim a irreparabilidade do dano no caso da demora, desde que exista fundamento relevante”.

32. **Nesse tópico, há mais uma contradição!**

33. Em havendo “fundamento relevante” – tal qual reconhecido na decisão – por certo haverá prognóstico provisório de sucesso para a concessão definitiva da segurança,



como um corolário consequente. **A propósito, os precedentes em anexo, consubstanciam a procedência da tese do direito líquido e certo da Impetrante.**

34. Portanto, afastar o perigo da demora sob o argumento de não se vislumbrar uma irreparabilidade do dano é uma manifesto equívoco, pois não se deve apenas deferir o pedido de liminar apenas quando houver indicação de uma ineficácia absoluta ao final, da medida, numa interpretação literal e restrita da redação do inciso III, do art. 7o, da Lei no 12.016/2009. **Ao contrário, havendo objetivamente risco de dano iminente, este não necessita ser irreparável, mas de difícil ou custosa reparação.**

35. Aliás, não se pode prescindir do quanto dispõe o art. 300, do CPC/2015, diante da imprescindível sistemática processual:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

36. Com melhor técnica, o art. 300, do CPC/2015, diz o que se deve extrair das entrelinhas do inciso III, do art. 7o da Lei no 12.016/2009.

37. Como se não bastasse, há graves riscos de danos severos e irreparáveis para a impetrante que não merecem ficar a mercê do tempo processual, até exsurgir uma sentença ou acórdão definitivo.

38. O Ato Coator está a submeter a Impetrante a uma inconstitucional e ilegítima exação a título de ITBI, conforme evidenciado na petição inicial, o que se comprova pela guia para recolhimento do tributo (Doc. 05) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, cujo valor, em 28 de maio de 2021, alcançava a importância de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos).

39. Dessa feita, a Impetrante vê-se impedida de transferir para si a propriedade imobiliária integralizada em seu capital pelo valor constate da declaração de bens de direitos do sócio Fernando de Abreu Júdice, sem que se submeta à exigência de qualquer valor a título de ITBI, nos exatos termos do que lhe garante a primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF c/c o inciso I, do art. 36, do CTN.



40. A propósito, o parágrafo 2o da Cláusula primeira do Instrumento de Alteração Contratual no 1 e Consolidação da Sociedade Limitada, registrado perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em 20.05.2020, estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que a Impetrante efetive a transferência dos imóveis que integralizaram o seu capital, a saber:

Parágrafo Quarto: A transferência efetiva da propriedade dos referidos bens imóveis, em favor da sociedade, será processada no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de efetivação do registro destes atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, devendo em igual prazo, serem arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, certidões imobiliárias, comprovando a transferência dos imóveis, restando assim concretizada a integralização do capital social da sociedade, ficando, no entanto, desde já, investida a Sociedade na posse direta sobre os bens, fazendo uso livre dos mesmos e deste tirando proveito.

41. Portanto, ultrapassado o prazo constante do contrato social para que tais transferências se efetivem, **a Impetrante ficará devedora de seus sócios e, ainda, vulnerável econômica e financeiramente em suas atividades, na medida em que não poderá fruir dos imóveis para efeito de garantias bancárias em operações de crédito, comprometendo, em demasia, a sua liberdade econômica, seus projetos comerciais e mercantis etc.**

42. Por sua vez, cada um dos sócios, uma vez afetados os imóveis à integralização, também não poderão se valer dos mesmos para efeitos comerciais outros e, tampouco, para obtenção de créditos bancários. Não obstante, os imóveis ainda não transferidos no Registro de Imóveis para o nome da Impetrante ficam juridicamente a mercê de responder pelas dívidas dos sócios, nos termos do quanto preveem o art. 391, CCB/20021 e art. 789, CPC/20152.

43. **Essa surreal situação não pode ser perenizar no tempo diante de uma ilegal exigência do ITBI, estabelecendo-se um verdadeiro engessamento da atividade empresarial, econômica e financeira da Impetrante.**

44. **Essa situação objetiva não é periclitante? O financiamento**

¹ Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

² Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.



bancário para atividades rurais da filial da Impetrante que deixa de ser concedido por falta de garantias não se reverte no tempo. Isso não é irrepristinável?

45. Não é demais lembrar o julgamento, pelo STJ, do REsp no 1.743.088/PR, a 3ª Turma, onde se decidiu que a simples inscrição do ato constitutivo da sociedade na Junta Comercial não é suficiente para efetivar a transferência da propriedade imobiliária à sociedade empresária, sendo absolutamente necessário o registro perante a matrícula no Cartório de Registro Geral de Imóveis.

46. É o que disciplina o art. 64 da Lei de Registro Público de Empresas Mercantis (Lei n. 8.934/94, ao dispor que *"[a] estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel devidamente individualizado, indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial"*.

47. Portanto, o contrato social, ainda que devidamente registrado na Junta Comercial, apenas constitui título translativo hábil à transferência da propriedade imobiliária, que somente se aperfeiçoa como determina o art. 1.245, do CCB/2002³.

48. Desse modo, quanto maior for o tempo de espera para a transferência do domínio perante o Cartório de Registro de Imóveis, mais vulnerável fica a Impetrante e seus sócios, estes em razão de que, por eventuais débitos seus, os imóveis integralizados, mas cujo domínio ainda não fora trasladado, continuam como parte integrante do seu patrimônio, podendo vir a ser constrictos por dívidas suas, diante da dinâmica dos fatos da vida.

49. Para além, deve-se alertar a Vossa Excelência, que a não-integralização do capital social, na sociedade limitada[5], implica responsabilização solidária de todos os sócios pelas obrigações contraídas pela sociedade empresária, até o limite do valor não integralizado, correspondente ao valor dos imóveis na hipótese em questão.

50. Nesse diapasão, de duas, uma: i) ou a Impetrante se sujeita à ilegal e à inconstitucional exação tributária para efeito de obter a competente certidão municipal para propiciar o traslado do domínio do imóvel perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis

³ Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.



competente; ii) ou, obtém a concessão de ordem mandamental, liminarmente e por sentença, para efeito de, uma vez reconhecido o seu direito líquido e certo à imunidade (não-incidência) do imposto municipal, em razão da integralização do imóvel no capital social da sociedade empresária, lograr transferir a propriedade imobiliária sem o indevido custo tributário, garantindo a sua normal sobrevivência e suas operações comerciais.

51. O tempo urge! E, a cada dia sem que o patrimônio integralizado não esteja devidamente transferido para o domínio da Impetrante a vulnerabilidade da sociedade empresária e de seus sócios se agiganta.

52. Eis o *periculum in mora*, a justificar a urgência para a concessão da tutela liminar a ser requerida, com espeque no art. 7º, III, da Lei no 12.016/2009, sob pena de, ao final, restar ineficaz quanto ao bem imóvel pretendido diante da vulnerabilidade patrimonial, à luz do disposto nos arts. 391, CCB/2002 e art. 789, CPC/2015. Essa possibilidade não é apenas virtual, mas sim real diante do que preveem a lei civil e a lei processual mencionadas.

53. Vale ressaltar, por derradeiro, que as jurisprudências citadas no corpo da decisão embargada para justificar a conclusão a que se chegou, data maxima venia, são imprestáveis para qualquer similitude com o caso sub judice, bastando a sua singela leitura e contraste com a hipótese dos autos.

54. Faz jus a Impetrante à concessão da ordem liminar.

55. Isto posto, requer a impetrante o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, para efeito de provê-los suprimindo as contradições e a omissão apontadas, para, ao final, conceder a tutela liminar nos moldes do pedido requerido, para suspender a exigibilidade da exação tributária com fundamento no art. 151, IV do CTN que, oficie-se a autoridade impetrada para que ciente da concessão da liminar, expeça a competente certidão para efeito de transferência da propriedade perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari.

56. Caso Vossa Excelência entenda por manter a decisão embargada, alternativamente, seja deferido o depósito do montante integral da exação tributária, tal qual previsto no art. 151, II, do CTN, o que constitui direito subjetivo do contribuinte, a fim de

Página 12 de 13

Rua Judith Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477 | www.abreujudice.com.br



suspender a exigência do crédito tributário, oficiando-se a autoridade impetrada para que, ciente do depósito, expeça a competente certidão para efeito de transferência da propriedade perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari.

57. Requer seja intimada a DD Procuradoria do Município de Guarapari a se manifestar previamente sobre os presentes Embargos de Declaração.

Termo em que aguarda e espera deferimento.

De Vitória/ES para Guarapari/ES, 02 de agosto de 2021.

RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE

OAB-ES 7.513

LUCIANA MARQUES DE ABREU JÚDICE

OAB-ES 5.868

RENAN DE ANGELI PRATA

OAB-ES 16.017

ENZO SCARAMUSSA COLOMBI GUIDI

OAB-ES 34.648



Petição de Embargos de Declaração



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL**

Mandado de Segurança nº 5002479-81.2021.8.08.0021

ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária já devidamente qualificada na petição inicial, por seus advogados constituídos, com elevado respeito à presença de Vossa Excelência, **nos autos da ação de Mandado de Segurança nº 5002479-81.2021.8.08.0021, impetrado em face do Sr. Secretário de Fazenda do Município de Guarapari/ES**, vem opor, com fulcro no art. 994, IV c/c art. 1022, I e II do CPC/2015, à luz da contradição e omissões detectadas, os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

consoante as razões abaixo expostas:

I – DA DECISÃO EMBARGADA

01. O presente writ foi ajuizado buscando a declaração da garantia da imunidade do ITBI quanto a operação de integralização (Art. 156, §2º, I da Constituição Federal), após decisão administrativa do Município de Guarapari que a negou.

02. O douto Juízo de direito em sede de sentença deferiu o pleito nos seguintes termos:



Ademais, embora a hipótese de imunidade versada nos autos seja incondicionada ("transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"), conforme a fundamentação supra, mostra-se oportuno consignar que não há nos autos qualquer indicativo de que a atividade preponderante da impetrante seja uma daquelas que encontra vedação no dispositivo constitucional para incidência da imunidade.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para DECLARAR a incidência de imunidade constitucional prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 43.799, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de excluir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 200.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 220 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00).

03. Entretanto, apesar do acerto da citada sentença, esta foi omissa ao deixar de analisar o pedido "b" do tópico VIII.2, qual seja:

b) também, no mérito, seja definitivamente reconhecido que a imunidade a que faz jus a Impetrante não encontra limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, uma vez incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF ("transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital").

II. MÉRITO RECURSAL

II. 1 OMISSÃO. FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO

04. Nos termos do artigo 1.022, II do Novo CPC, cabe embargos de declaração contra decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

05. Consoante a decisão acima trazida, é possível verificar que ao proferir sentença, o Juízo somente analisou uma das causas de pedir/pedido da Embargante carecendo ainda, o pedido referente as limitações constantes nos parágrafos 1º e 3º do art. 37 do CTN.

06. Nesse sentido, o Código de Processo Civil explicita, ainda, no parágrafo único do art. 1.022 as hipóteses em que deve ser considerada omissa a decisão, prevendo

Página 2 de 3

Rua Judith Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477 | www.abreujudice.com.br



expressamente o inciso II que as condutas previstas no art. 489, §1º, do CPC, incorrem na mencionada irregularidade.

07. Dentre as hipóteses apresentadas no §1º do art. 489 do CPC e que maculam a decisão judicial com o vício da omissão, o inciso IV, traz a seguinte disposição:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

08. No caso em análise o MM. Juiz deixou de apreciar o supracitado pedido, sendo que os referidos artigos foram utilizados como fundamentos do ato coator da municipalidade, motivando a oposição dos presentes embargos de declaração.

III. DOS PEDIDOS

09. Diante do exposto, requer seja sanada a omissão na r. sentença que julgou o feito e, conseqüentemente, reconhecido que a imunidade a que faz jus a Impetrante não encontra limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, uma vez incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF ("transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital").

Nestes termos, pede deferimento

De Vitória/ES para Guarapari/ES, 28 de outubro de 2021.

RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE

OAB-ES 7.513

LUCIANA MARQUES DE ABREU JÚDICE

OAB-ES 5.868

LEONARDO GONORING GONÇALVES SIMON

OAB-ES 18.844

ENZO SCARAMUSSA COLOMBI GUIDI

OAB-ES 34.648



Apelação



AO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARAPARI – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Mandado de Segurança nº 5002479-81.2021.8.08.0021

ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária, devidamente qualificada nos autos epigrafados, vêm tempestivamente, por intermédio de seus advogados *in fine* assinados, perante Vossa Excelência, interpor, com esteio nos arts. 1.009; e 1.013, §3º do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO

Em face da r. sentença que, deixou de analisar o pedido “b” do tópico VIII.2, pelo que apresenta as razões de fato e os fundamentos de direito, requerendo recebimento e processamento, perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2021

Rodrigo Marques de Abreu Júdice

OAB/ES nº 7.513

Luciana Marques de Abreu Júdice

OAB/ES nº 5.868

Leonardo Gonoring Gonçalves Simon

OAB/ES nº 18.844

Enzo Scaramussa Colombi Guidi

OAB/ES nº 34.648



RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO

Mandando de Segurança nº: 5002479-81.2021.8.08.0021

Recorrente: Abreu Júdice Participações LTDA

Recorrida: Secretário de Fazenda do Município de Guarapari

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,

Colenda Câmara,

Eméritos Desembargadores,

I – DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPRO

1. A Apelante foi intimada, do teor da Sentença ora atacada em 22/11/2021 (ID nº 1326801).

2. Considerando que a abertura do prazo se deu em 22/11/2021, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação estabelecido nos art. 1.003, § 5º, do CPC, tem como dies ad quem a data de 14/12/2021. Portanto, é tempestivo o presente recurso.

3. A Apelante informa ainda que as custas recursais no valor de R\$ 492,20 (quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos) foram recolhidas conforme demonstra o comprovante de pagamento anexo. Restando assim, o presente recurso devidamente apto a ser conhecido e julgado por este Egrégio Tribunal.

II – SÍNTESE PROCESSUAL

4. A Apelante, ajuizou Mandado de Segurança almejando obter a garantia de imunidade quanto ao ITBI, disposta no art. 156, §2º, I da Constituição Federal, diante de



operação de integralização de capital societário da pessoa jurídica Abreu Júdice Participações LTDA.

5. Registre-se que o competente juízo de piso acertadamente constata na Sentença que a imunidade pleiteada é incondicionada, assim, deferiu o pleito nos seguintes termos:

Ademais, embora a hipótese de imunidade versada nos autos seja incondicionada ("transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"), conforme a fundamentação supra, mostra-se

oportuno consignar que não há nos autos qualquer indicativo de que a atividade preponderante da impetrante seja uma daquelas que encontra vedação no dispositivo constitucional para incidência da imunidade.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para DECLARAR a incidência de imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 43.799, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 200.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 220 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00).

6. Ocorre que, embora reconhecida como incondicional a imunidade pretendida e, que a segurança almejada tenha sido, corretamente, concedida, a Sentença foi omissa quando deixou de analisar um dos pedidos contidos no Mandado de Segurança. O pedido "b" do tópico VIII passou despercebido pelo julgador.

b) também, no mérito, seja definitivamente reconhecido que a imunidade a que faz jus a Impetrante não encontra limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, uma vez incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF ("transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital").



7. Diante da clara omissão destacada nos parágrafos anteriores, a Apelante tentou por meio de Embargos de Declaração sanar tal vício, porém, não logrou êxito pois o nobre julgador negou provimento aos embargos. Vejamos:

Não há necessidade, assim, e disto não decorre omissão, de emissão de uma declaração apartada acerca da não submissão da imunidade que foi reconhecida no dispositivo da sentença às limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, porque incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

À luz do exposto, porque desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes NEGO PROVIMENTO.

8. Logo, imprescindível se torna a interposição do presente recurso para que seja reformada a sentença de piso e, assim, seja concedida a imunidade prevista no art. 156, §2º, I da CF/88, afastando a limitação tipificada nos arts. 36. I, II; e 37 do Código Tributário Nacional.

II – RAZÕES DO RECURSO

9. Antes de adentrarmos ao mérito recursal propriamente dito, diante da relativa complexidade da matéria abordada, pedimos vênica para enfatizarmos a tese acolhida em sede de sentença,

II. 1 DA TESE ACOLHIDA PELA SENTENÇA - RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE INCONDICIONADA PREVISTA NO ART. 156, §2º DA CF/88 PELA SENTENÇA

10. A matéria apresentada diante do MS tem índole diretamente constitucional. A propósito, eis a dicção dos preceitos constitucionais que regem o tema:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:



I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

11. O inciso II do art. 156 da CF/88, em sua redação, prevê ser de competência dos Municípios a instituição de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) inter vivos, bem como de direitos reais sobre imóveis e cessão de direito a sua aquisição.

12. Entretanto, o dispositivo constitucional, em seu §2º, inciso I, traz uma regra imunizante ao afirmar que o ITBI "*não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital*". Observa-se que, nesse preceito, condizente com a primeira hipótese de imunidade, não há qualquer ressalva ou exceção estabelecida pelo texto constitucional.

13. É o que ocorre no caso sob judice com a integralização do imóvel pertencente ao sócio da Impetrante, Fernando de Abreu Júdice. O imóvel foi integralizado pelo valor constante da declaração de bens (R\$ 220.00,00) e transformado em quotas proporcionais, ou seja, em 220 mil quotas referente ao respectivo imóvel.

14. **O imóvel em epígrafe integraliza o capital social da impetrante pelo exato valor constante da declaração de bens dos sócios, correspondendo à mesma grandeza em termos de quotas subscritas, não havendo qualquer diferença a maior, ou a menor. Não houve, portanto, discrepância entre o patrimônio da sociedade e o seu capital, no pormenor; e, tampouco, ficou registrado parte do valor à conta de reserva de capital ou de ágio.**

15. Por sua vez, a leitura da regra constitucional nos permite detectar imunidade tributária para duas situações, e uma exceção apenas para a segunda situação prevista:



- a) criação de empresa com a integralização pelos sócios de imóveis seus para a realização de capital e
- b) sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

16. A única exceção para a aplicação da regra imunizante e, assim, permitir a incidência do tributo, **reside na hipótese de a atividade preponderante da empresa adquirente**, nos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, **"for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil"**. E essa exceção à regra imunizante aplica-se somente à segunda parte do texto, nos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, o que, também, não é a hipótese com a qual se depara a impetrante.

17. Dito isso, pode-se afirmar, adiantando-se ao que será detalhadamente exposto, não ter sido recepcionado o art. 37 do Código Tributário Nacional para a hipótese primeira constante da parte inicial da locução normativa: **"não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"**.

18. **O art. 37 do CTN só tem, atualmente, aplicação para as hipóteses previstas na segunda locução da regra constitucional, que corresponde ao inciso II, do art. 36, e, assim, a imunidade deixará de existir**¹. Observemos a

¹Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.



locução do texto constitucional: **"nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil"**.

19. Essa moldura interpretativa ficou adequadamente assentada pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento do **Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, Tema 796**, em regime de Repercussão Geral, quando a maioria de seus membros acompanhou o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, pelo que, desde já, afirma-se que a ilustre Procuradoria do Município de Guarapari fez uma inadequada leitura dos votos proferidos, bem como da tese estabelecida e, principalmente, da *ratio decidendi* do julgamento.

20. Diante dos argumentos apresentados nos parágrafos anteriores, o competente juízo, em sede de Sentença, constata corretamente como incondicionada a imunidade pleiteada. Deferindo o pleito nos seguintes termos:

Ademais, embora a hipótese de imunidade versada nos autos seja incondicionada ("transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"), conforme a fundamentação supra, mostra-se

oportuno consignar que não há nos autos qualquer indicativo de que a atividade preponderante da impetrante seja uma daquelas que encontra vedação no dispositivo constitucional para incidência da imunidade.

Ante o exposto, **CONCEDO A SEGURANÇA** para DECLARAR a incidência de imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 43.799, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezesete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 200.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 220 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00).

21. Observa-se, o embora reconhecida como incondicional a imunidade pretendida e, que tenha sido corretamente concedida a segurança almejada diante do MS, a

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.



Sentença é omissa, pois, deixou de analisar um dos pedidos contidos na exordial. Tal qual o pedido "b" do tópico VIII.2, já evidenciado em tópico anterior.

22. Isto posto, passamos ao próximo tópico onde serão lançados os argumentos processuais que se alinham a vontade de reforma da Sentença ora atacada.

II.2 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO APELADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 489, IV E 490 DO CPC

23. Consoante a decisão acima recortada, é possível verificar que, ao proferir a Sentença, o juízo analisa somente uma das causas de pedir/pedido, se omitindo por completo ao deixar de analisar o pleito referente as limitações previstas no art. 37, §1º, e §2º do CTN.

24. Nesse sentido, o Código de Processo Civil explicita que, todos os argumentos levantados no processo devem ser combatidos pelo julgador, de modo que tal protocolo é tido como elemento essencial da Sentença e, quando ausente, configura-se não fundamentada a decisão judicial, tornando-a defeituosa.

25. O artigo 489 do CPC impõe que a situação descrita acima é considerada como não fundamentada, vejamos:

Art. 489 (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

26. Na mesma senda, a Sentença proferida pelo nobre julgador atenta contra o art. 490² do CPC, que determina que o magistrado ao analisar o mérito deve acolher

²Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.



ou rejeitar, todo ou em parte, os pedidos pleiteados pelas partes – o que não ocorre na Sentença guerreada.

27. Observe-se que a decisão objurgada justifica a não existência de omissão com relação ao *pedido "b" do tópico VIII.2* em razão do mesmo encontrar-se implicitamente acolhido.

Não há necessidade, assim, e disto não decorre omissão, de emissão de uma declaração apartada acerca da não submissão da imunidade que foi reconhecida no dispositivo da sentença às limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, porque incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

28. Ora, nos exatos termos das supracitadas normas, o ordenamento jurídico vigente não permite fundamentação implícita.

29. Sobre o tema, o nobre doutrinador Alexandre Câmara é assertivo:

A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam, juridicamente, a conclusão a que se tenha chegado. Este é um ponto essencial: **fundamentar é justificar**. É que a decisão precisa ser legitimada democraticamente, isto é, a decisão precisa ser constitucionalmente legítima. **Para isso, é absolutamente essencial que o órgão jurisdicional, ao decidir, aponte os motivos que justificam constitucionalmente aquela decisão, de modo que ela possa ser considerada a decisão correta para a hipótese.** E esses fundamentos precisam ser apresentados substancialmente. Afinal, se os direitos processuais fundamentais (como o direito ao contraditório ou o direito à isonomia) têm de ser compreendidos em sua dimensão substancial – e não em uma dimensão meramente formal –, o mesmo deve se aplicar ao direito fundamental a uma decisão fundamentada. **O que se pretende dizer com isso é que não terá sido observado o princípio constitucional da fundamentação das decisões se o pronunciamento judicial contiver uma fundamentação meramente formal, que é a rigor um simulacro de fundamentação, ou seja, uma fundamentação fictícia.** Afirmações como “presentes os requisitos, defere-se a medida”, ou “indefer-se por falta de amparo legal” não são verdadeiras fundamentações, porque não justificam as decisões. **Por que se podem considerar presentes os requisitos? E que requisitos são esses? O que significa “falta de amparo legal”? Há alguma vedação? Onde está a proibição? Por que ela se aplica ao caso? Nenhuma dessas perguntas é respondida por fundamentações simuladas, fictícias, como as que foram indicadas acima.**



30. A fundamentação das decisões se trata de pressuposto constitucional trazido no art. 93, IX da Constituição Federal sendo cláusula essencial para administração do Poder Judiciário do país.

31. Para melhor exemplificação vale citar a doutrina de Cássio Scarpinella Bueno³:

Todas essas hipóteses previstas no parágrafo primeiro do art. 489 podem ser reduzidas a ausência de fundamentação e geram nulidade da sentença. Isto porque "fundamentação" deficiente, em rigor, não é fundamentação (pelo menos não o é daquele decisório). O art. 489, parágrafo primeiro, do novo CPC enuncia hipóteses nas quais não se considerará fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela acórdão, sentença, decisão interlocutória, consagrando a concepção de que decisão inadequadamente fundamentada é decisão não fundamentada.

32. Ademais, há de ser destacado que o parecer acolhido pela decisão administrativa, ato abusivo e ilegal, faz expressa menção à ressalva contida nos §§ 2º e 3º do Art. 37, do CTN, o que demonstra a imperiosa necessidade de que o reconhecimento da imunidade incondicionada traga expressa menção aos referidos dispositivos.

subsequentes à aquisição, ou nos três anos seguintes à aquisição, caso caracterizada a hipótese do §3º do art. 36 do CTN.

7. Tratando-se de pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos⁴, a exoneração do tributo ficará condicionada durante o triênio seguinte à aquisição, convalidando-se, a depender da atividade preponderante, depois dele: em suma, o imposto ficará diferido⁵ até que se complete o termo⁵.

33. Isso porque, na eventualidade da Impetrante desejar alterar o seu objeto social, para fazer constar a compra, a venda e a locação de imóveis como atividade preponderante antes dos dois anos de sua instituição, não precise ter que movimentar novamente a máquina judiciária para que seu direito líquido e certo também trazido à baila em sede do presente mandado de segurança. Essa hipótese não nos afigura plausível, tampouco prestigia a boa administração da justiça.

³ BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil. Ed: Saraiva, São Paulo, 2018.



34. Dessa forma, é possível perceber que a sentença é nula, por deixar de apreciar um dos pedidos da Apelante, assim como por evidente ausência de fundamentação, devendo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo julgar o mérito, conforme o art. 1.013, §3º, III⁴ do CPC.

III – CONCLUSÃO

35. Por todo exposto requer que seja CONHECIDA e PROVIDA a apelação para reformar a r. sentença no ponto que se fez omissa, de modo que seja também julgado procedente o *pedido "b" do tópico VIII.2*, concedendo a imunidade prevista no art. 156, §2º, I da CF/88, afastando as limitações tipificadas nos arts. 36, I, II; e 37 do CTN.

Nestes termos,
PEDE DEFERIMENTO.

Vitória/ES, 14 de dezembro 2021.

Rodrigo Marques de Abreu Júdice

OAB/ES nº 7.513

Luciana Marques de Abreu Júdice

OAB/ES nº 5.868

Leonardo Gonoring Gonçalves Simon

OAB/ES nº 18.844

Enzo Scaramussa Colombi Guidi

OAB/ES nº 34.648

Miguel Arcanjo de Paula Netto

Estagiário de Direito

⁴ Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Ref. APELAÇÃO Nº: 5002479-81.2021.8.08.0021

RECORRENTE: Município de Guarapari/ES

RECORRIDA: Abreu Judice Participações LTDA

MUNICÍPIO DE GUARAPARI, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vêm, por seu procurador infra-assinado, perante Vossa Excelência, com amparo no artigo 102, inciso III, alínea “a” da CRFB/88, interpor o presente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

irresignado com o v. acórdão de **ID 5330855**, publicado em 21/07/2023, com ciência eletrônica em 31/07/2023, prolatado na Apelação nº **5002479-81.2021.8.08.0021**, proferido pela Egrégia 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na forma do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, fundamentado nas razões anexas, pelo que, admitido e processado regularmente, requer seja o presente recurso submetido a julgamento perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal.

NESTES TERMOS, PEDEM DEFERIMENTO.

Vitória | ES | 14 | setembro | 2023.

LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE
Procuradora Municipal
OAB/ES n.º 10.673
Matrícula n.º 302261-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ref. APELAÇÃO Nº: 5002479-81.2021.8.08.0021

RECORRENTE: Município de Guarapari/ES

RECORRIDA: Abreu Judice Participações LTDA

R A Z Õ E S R E C U R S A I S

COLEND A TURMA
EXCELENTÍSSIMOS MINISTROS,

I. ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO

I.1) Tempestividade e preparo

1. O presente recurso alcança os requisitos de forma e de tempestividade em sua totalidade, obedecendo exatamente às condições determinadas no art. 1.029 e seguintes CPC.
2. Considerando as publicações, o prazo de 15 dias em dobro findar-se-á na data de hoje – 14/09/2023 conforme verifica-se no próprio PJE, senão vejamos:

ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA	22/08/2023 23:59:59 (para manifestação)	SM
Expedição eletrônica (21/07/2023 13:23:33) O sistema registrou ciência em 21/07/2023 23:59:59 Prazo: 15 dias		
Audiência (213641)		
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	05/09/2023 23:59:59 (para manifestação)	SM
Representante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo Expedição eletrônica (21/07/2023 13:23:33) Gestor MPES MHI registrou ciência em 24/07/2023 13:52:09 Prazo: 30 dias		
Audiência (213642)		
MUNICIPIO DE GUARAPARI	14/09/2023 23:59:59 (para manifestação)	NÃO
Representante: Procuradoria do Município de Guarapari Expedição eletrônica (21/07/2023 13:23:33) O sistema registrou ciência em 21/07/2023 23:59:59 Prazo: 30 dias		

3. Destaca-se que houve suspensão de prazos processuais em razão de feriados de 11 de agosto e 07 e 08 de setembro de 2023, como verifica-se da resolução do TJES. Portanto, protocolizado até a data, **o presente recurso é tempestivo**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Ato Normativo 220/2022

Categoria: Atos Normativos
Data de disponibilização: Quinta, 10 de Novembro de 2022
Número da edição: 6728
Replicações: [Clique aqui para ver detalhes](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PJES
RUA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA,60 - Bairro ENSEADA DO SUÁ - CEP 29050906 - Vitória - ES - www.tjes.jus.br

MINUTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA GERAL

ATO NORMATIVO Nº 220/2022

O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a existência de feriados decretados em lei,

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário deve estabelecer com antecedência o calendário de funcionamento das repartições que lhe são subordinadas,

RESOLVE:

Art. 1º. Publicar a relação de feriados do ano de **2023**, conforme **Anexo Único**, de abrangência em todo o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo dos feriados de cada Município sede de Comarca e/ou Juízo.

Art. 2º. A data de *Corpus Christi*, dia **08 de junho de 2023** (quinta-feira), será considerada ponto facultativo nas unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo localizadas em Municípios onde não houver lei específica que já a considere feriado.

Parágrafo único. A data de **09 de junho de 2023** (sexta-feira) será considerada ponto facultativo em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Art. 3º. Os dias não trabalhados nos pontos facultativos devem ser compensados ao longo dos dias úteis seguintes, por meio da extensão da jornada de trabalho em 01 (uma) hora, cabendo às chefias imediatas a atribuição de observar o rigoroso cumprimento da carga horária.

Art. 4º. Os efeitos deste Ato não se aplicam às Serventias Extrajudiciais.

Publique-se.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira
Presidente

ANEXO ÚNICO – FERIADOS DO ANO DE 2023

(...)

Agosto

11 (sexta-feira) – Dia do Advogado (art. 141, "d", da Lei Complementar Estadual nº 234/2002)

Setembro

07 (quinta-feira) – Independência do Brasil (art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002)

08 (sexta-feira) – Ponto Facultativo (e Feriado de Nossa Senhora da Vitória no Município de Vitória/ES, conforme art. 1º da Lei Municipal nº 1.732/1967)

4. Como sabido, o Município possui prerrogativa de pagamento ao final do processo de eventuais custas de sua responsabilidade, estando, portanto, preenchido requisito do preparo recursal.

I.2) Cabimento do recurso extraordinário e prequestionamento

5. Conforme já asseverado, o presente recurso extraordinário tem como fundamento o artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal¹, e viola normas

¹ **Constituição Federal.** Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

previstas na Constituição federal, e ainda altera entendimento adotado pelo próprio Excelso Pretório, como restará demonstrado.

6. Como adiante especificamente demonstrado, o acórdão recorrido viola frontalmente o artigo 156 § 2º, inciso I da Constituição combinado com art. 36, I, CTN, artigos estes que foram analisados expressamente pelo acórdão ora recorrido (fls.05 do voto constante no ID 5330855).

7. Dessa forma, se delimita como objeto da discussão deste recurso a negativa de vigência ao art. 156 § 2º, inciso I da Constituição Federal.

8. Acerca do pré-questionamento, tem-se que em todos os votos proferidos durante a discussão de julgamento analisaram exaustivamente o dispositivo de lei *sub judice*, de forma expressa, o que facilmente percebe-se ao logo das fundamentações.

I.3) Da desnecessidade de reanálise fático-probatória – não incidência do óbice do Enunciado da Súmula 279 deste e. STF

9. Além do cumprimento dos pressupostos citados nos tópicos acima, importante destacar, ainda, que a matéria tratada no presente recurso extraordinário não demanda o reexame fático probatório a ensejar a aplicação da Súmula 279 deste E. STF, uma vez que as balizas fáticas na qual se funda o direito do Município Recorrente foram devidamente reconhecidas pelo v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do E. TJES.

10. Pois bem.

11. O que se pretende com a interposição do presente recurso é o reconhecimento da existência de condições para configuração da imunidade tributária prevista no art. 156 § 2º, inciso I da Constituição Federal, não podendo afirmar-se que se trata de uma imunidade incondicional, como fez o Tribunal *a quo*.

12. Para isso, basta a simples leitura do texto constitucional e da interpretação já delineada por este Excelso STF no ARE 1316381 para se concluir pelo desalinhamento do acórdão recorrido com a análise deste Tribunal, vez que não houve no julgamento do tema 796 alteração do entendimento quanto a condição acerca da atividade da empresa. Cita-se:

“[...] a pretensa aplicação do **RE 796.376-RG** ao caso em exame não merece acolhida. **No julgamento do referido paradigma, o Plenário do STF decidiu que, na integralização do capital social por meio de bens**

recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; (...) c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

imóveis, a diferença de valor que superar o capital subscrito a ser integralizado será tributada pelo ITBI. Diferentemente, na hipótese destes autos, a Corte de origem concluiu pela inaplicabilidade da regra imunitória em razão de controvérsia acerca da atividade preponderante exercida pela empresa, aferida mediante análise de sua receita operacional. Portanto, a matéria discutida no RE 796.376-RG não guarda semelhança com a questão posta no presente recurso. [...]. (ARE 1316381 ED- segundos, Relator(a): Min. Roberto Barroso, j. 16/08/2021)

13. O que se verifica é que o E. Tribunal *a quo* chegou à conclusão jurídica diversa do entendimento do Eg. STF, sendo a questão eminentemente de direito.

II. DA REPERCUSSÃO GERAL

14. Resta por fim ainda essencial destacar a clara existência de repercussão geral no caso.

15. No Leading Case [RE 796376](#), a repercussão geral foi admitida sob o seguinte fundamento:

Plenário Virtual
PRONUNCIAMENTO

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO ITBI IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:

Submeto a Vossa Excelência o tema versado no Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, para exame da oportunidade de inclusão da matéria no sistema eletrônico da repercussão geral.

O processo revela mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Município, consistente na negativa de emissão da guia para recolhimento do Imposto de Transmissão Inter Vivos ITBI, referente aos imóveis integralizados ao capital da empresa, com a imunidade total prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. A autoridade administrativa justificou a negativa no fato de o valor total dos imóveis exceder em muito o capital integralizado. O Juízo implementou a liminar, confirmando-a na sentença, para reconhecer a imunidade e determinar que a autoridade coatora se absteresse de cobrar o referido tributo.

A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, à unanimidade, deu provimento à apelação do Município e à remessa necessária, para indeferir a ordem. Observou restringir-se a imunidade estabelecida no artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta da República ao valor do imóvel suficiente à integralização do capital social. Afirmou que a intenção do constituinte foi facilitar a criação de novas sociedades e a movimentação dos bens correspondentes ao respectivo capital. Consignou haver, no artigo 36 do Código Tributário Nacional, menção de que a não incidência estaria restrita ao capital subscrito, não sendo razoável a concessão de imunidade quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente. Assentou que





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

a empresa não atua no comércio de imóveis, inexistindo razão para a incorporação de bens de quantia superior ao valor nominal das cotas. Concluiu pela imunidade apenas do valor referente à parcela dos imóveis necessária à integralização do capital social, incidindo o ITBI sobre a parte que exceder.

O acórdão impugnado encontra-se assim resumido:

TRIBUTÁRIO - ITBI - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, INCISO II, DA CF/1988) - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS RESPECTIVOS - IMUNIDADE QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL E DAS COTAS INTEGRALIZADAS COM IMÓVEIS - EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

A imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso II do § 2º do art. 156, da Constituição Federal de 1988 impede a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis "inter vivos" somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Vale dizer, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá incidência do tributo.

Os embargos declaratórios foram desprovidos.

No extraordinário, protocolado com alegada base nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a empresa argui ofensa aos artigos 1º, 5º, incisos II e XXXVI, 37, cabeça, 156, § 2º, inciso II, e 170, inciso IV, do Diploma Maior. Sustenta não haver, na Carta Federal, qualquer limitação no tocante à observância da imunidade do ITBI na realização de capital, não podendo o Fisco nem o Poder Judiciário restringir a incidência, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Segundo aduz, a sociedade empresária foi regularmente formalizada, consubstanciando ato jurídico perfeito, e esclarece que outro Município do mesmo Estado tem reconhecido a imunidade sem qualquer ressalva, o que gera insegurança jurídica.

Ressalta que a Carta de 1988, ante o princípio da livre iniciativa, previu a mencionada imunidade com o objetivo de facilitar a entrada de pessoas naturais e jurídicas no mercado, permitindo a integralização de capital social não só mediante a disponibilidade de dinheiro, mas também por meio de transmissão de bens imóveis sem a incidência de imposto. Sublinha ser a maioria do empresariado brasileiro representado por pequenas e médias empresas que não possuem capital elevado. Aponta a incoerência de possibilitar um benefício fiscal sem que seja viável a grande parte dos cidadãos. Defende que o dinamismo das relações societárias não deve encontrar obstáculos no Estado, salvo nos casos descritos em lei, pois ele depende do mercado para arrecadar tributos e, assim, desenvolver políticas públicas.

Salienta haver cumprido os requisitos estabelecidos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional para o reconhecimento da aludida imunidade, a qual deve ser considerada uma vedação absoluta ao poder de tributar. Diz da impossibilidade de o Tribunal de origem presumir que a intenção da empresa não é a integralização do capital e enfatiza ser o contrato social uma relação entre particulares, na qual predomina a autonomia da vontade. Esclarece que, de acordo com o ato constitutivo, a diferença entre o valor dos imóveis e a quantia integralizada será contabilizada como reserva de capital.

Sob o ângulo da repercussão geral, afirma ultrapassar o tema o interesse subjetivo das partes, mostrando-se relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico. Assinala que a matéria é de interesse das sociedades empresárias constituídas e aponta a necessidade de definir-se o alcance da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta da República.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

O extraordinário foi admitido na origem.

Atendeu-se aos pressupostos gerais de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal. O preparo encontra-se devidamente comprovado.

2. Ante o disposto no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assentou que a imunidade incide somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. O preceito constitucional prevê:

[...]

[...]

I não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesse caso, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

[...]

Eis tema a reclamar o crivo do Supremo, definindo-se o alcance da norma, ou seja, cabe ao guarda maior da Lei das Leis elucidar se o dispositivo contempla limitação à imunidade considerado o Imposto de Transmissão Inter Vivos.

3. Pronuncio-me no sentido de ter como configurada a repercussão geral. Uma vez admitida, colham o parecer da Procuradoria Geral da República, visando a apreciação da controvérsia e, portanto, o julgamento do recurso extraordinário.

4. À Assessoria, para acompanhar a tramitação do incidente, inclusive quanto aos processos que, no Gabinete, versem a mesma matéria.

5. Publiquem.

Brasília residência, 11 de fevereiro de 2015, às 10h15.

Ministro MARCO AURÉLIO

Relator

16. Facilmente percebe-se a importância do tema, não só para os empresários que precisam ter certeza jurídica para empreenderem no país, mas também para os Municípios que possuem competência tributária para exigir tributo sobre referida integralização, de modo que a completa interpretação do tema é condição *sine qua non* para harmonizar as relações contribuintes e Municípios de todo Brasil.

17. Cumpre destacar que o Poder Judiciário brasileiro está repleto de ações acerca do referido tema, nas quais inúmeros Municípios discutem a matérias, inclusive com vários posicionamentos díspares.

18. Por óbvio que o tema objeto do presente ultrapassa em muito um interesse subjetivo das partes, devendo ser admitida sua análise por este Eg. Supremo Tribunal, a fim de pacificar as relações contribuintes X Municípios brasileiros.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

IV. BREVE SÍNTESE DOS AUTOS:

19. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora recorrida, na qual pretende ver declarada a imunidade absoluta e incondicional quanto ao ITBI incidente sobre a diferença entre o valor da transferência declarada na integralização de capital, e o valor de avaliação do Município. Vejamos:

Seja reconhecido o direito líquido e certo de a impetrante fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre transmissão do apartamento no 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, neste município, incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sem qualquer reserva de valor à conta de capital ou de ágio, prevalecendo o valor constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 220.000,00 – duzentos e vinte mil reais), e como tal integralizado como capital da sociedade empresaria em 220 – duzentos e vinte – mil cotas, afastando, definitivamente e por completo, a exação de R\$ 17.690,11 (dezesete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), em 28.05.2021, ou qualquer outra a ser apurada, ilegalmente, sobre a diferença entre o valor do imóvel acima destacado, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00 – oitocentos e oitenta mil reais);

20. Por conseguinte, sem qualquer apuração de fatos pois trata-se de mandado de segurança, foi proferida sentença, a qual foi integralmente mantida pelo acórdão ora guerreado, sob os seguintes fundamentos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002479-81.2021.8.08.0021
APELANTE: ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como sumariamente relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por Abreu Júdice Participações Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente (id 2503672) que, no mandado de segurança impetrado em face do Secretário da Fazenda do Município de Guarapari, concedeu a segurança para “declarar a incidência de imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio a impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 43.799, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezesete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 200.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 220 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00)”. Em sua peça recursal (id 2503693), a sociedade empresária aduz, em síntese,





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

haver omissão quanto ao pedido “b”, da petição inicial, pelo qual requer seja “definitivamente reconhecido que a imunidade a que faz jus a Impetrante não encontra limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, uma vez incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF (transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital)”. Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame do seu mérito, em conjunto com a análise da remessa necessária. Isso porque se trata de sentença concessiva de segurança, estando sujeita, pois, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição, por imposição do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresária, ora apelante, por meio do qual pretende seja reconhecido o seu direito líquido e certo de fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre transmissão do apartamento nº 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na Avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. A discussão a respeito da incidência, ou não, da imunidade tributária decorre do fato de o Município de Guarapari, em processo administrativo, ter avaliado o bem no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), ao passo que a quantia informada pelo contribuinte, nos termos da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice, foi de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Nesse contexto, o Fisco Municipal entendeu que haveria a incidência do ITBI sobre a diferença equivalente a R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), visto que o Supremo Tribunal Federal teria entendimento consolidado no sentido de que a imunidade não alcançaria o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Sobre o tema, isto é, acerca do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, não é demais rememorar que, ao distribuir a competência impositiva entre os entes tributantes, nossa Carta Maior outorgou aos Municípios a competência para instituir o imposto sobre a “transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição” (art. 156, inc. II), demarcando, com isso, os comportamentos suscetíveis de serem colhidos pelo legislador como hipótese de incidência do aludido tributo.

Acontece que a própria Carta Magna, no mesmo dispositivo, estabelece a não incidência do ITBI em certas operações societárias, instituindo hipóteses de imunidade objetiva, que visam estimular a capitalização e o crescimento das empresas.

Deveras, o inciso I do §2º do citado artigo 156, preconiza que:

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Da redação do supratranscrito dispositivo legal, é possível constatar que sobre a transmissão de bens ou direitos imobiliários incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, seja (i) para a integralização do capital social ou (ii) em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não incide o ITBI, desde que, “nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

O texto constitucional, portanto, impõe uma condicionante para a não incidência do tributo, consistente no fato de que a atividade empresarial preponderante da pessoa jurídica adquirente não se enquadre como a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Neste particular, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, Repercussão Geral – Mérito Dje-210, Divulg 24-08-2020 Public 25-08-2020), definiu que a imunidade referente ao ITBI para integralização de bens imóveis no capital social da empresa não é absoluta, sendo limitada ao valor do capital fixado, de sorte que montante excedente está sujeito à tributação.

Todavia, ao fixar a tese de repercussão geral, o Pretório Excelso não fez nenhuma ressalva quanto à diferenciação da atividade empresarial para fins de excluir aquelas que atuem no ramo imobiliário.

Pelo contrário, o que se observa do voto condutor do acórdão, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, é que o tema atinente à atividade preponderante da pessoa jurídica foi expressamente enfrentado pela c. Corte, segundo a qual “as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica”.

Como se sabe, dentro da sistemática de precedentes judiciais adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, a doutrina especializada nos ensina que são as razões de decidir dos precedentes que operam a vinculação - “extraí-se da ratio decidendi, por indução, uma regra geral que pode ser aplicada a outras situações semelhantes. Da solução de um caso concreto (particular) extraí-se uma regra de direito que pode ser generalizada” (In Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil – 11 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v.2, p. 460). Seguindo essa linha de inteligência, não há como deixar de reconhecer que a maioria do STF, naquela ocasião, entendeu pela necessidade de se distinguir os significados de “incorporação de bens em realização de capital” e “incorporação de bens ao patrimônio”, expressões utilizadas, respectivamente, na primeira e segunda oração do artigo do Texto Maior. Para os ministros, a primeira situação constitui unidade incondicionada, pois somente no segundo caso é que a imunidade se limita às hipóteses em que a sociedade incorporadora do patrimônio imobiliário não desenvolva atividade preponderantemente imobiliária.

A simples leitura da íntegra do acórdão é suficiente para constatar que a ratio decidendi do precedente em questão está calcada na imprescindível distinção entre as duas hipóteses de imunidade previstas no art. 156, §2º, I, da CF, eis que o voto vencedor é enfático neste ponto, dedicando vários parágrafos se chegar a tal conclusão. Não se trata, pois, de mero obter dictum, mas sim da interpretação





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

dada pelo Pretório Excelso ao referido dispositivo constitucional.

Aliás, vale registrar que não houve declaração implícita de inconstitucionalidade do art. 37 do CTN, mas tão somente interpretação conforme a Constituição, de modo a preservar validade da lei, indicando a leitura da norma que melhor se coaduna com a Carta Magna. Destarte, de acordo com o novo posicionamento do STF, é preciso compreender que a exceção estipulada no art. 37 do CTN alcança apenas as hipóteses previstas no inciso II do art. 36 daquele diploma, eis que as situações constantes em seu inciso I são imunes de ITBI independentemente de qualquer condicionante.

Logo, é de se concluir que, muito embora não conste na redação da tese de repercussão geral, o Supremo de fato decidiu expressamente, no julgamento do Tema nº 796, que a imunidade prevista na primeira parte do art. 156, §2º, inciso I, da CF/88 – transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital – é incondicionada, porquanto independe da atividade empresarial exercida pela adquirente.

Ademais, conforme bem explicitado pela sentença, a regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário.

Até mesmo porque a lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, ao dispor sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável, senão vejamos:

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital. (g.n)

Conquanto a supracitada lei verse sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas, fato é que o seu teor serve para demonstrar a inocorrência de ato ilícito por parte da sociedade empresária e de seu sócio. Pelo contrário, a legislação pátria lhes confere a faculdade de optar por esta forma de integralização do capital social, de modo que a conduta do Município apelado, além de afrontar dispositivo constitucional, acaba por indevidamente frustrar essa opção do contribuinte legalmente permitida. É dizer, todo o imóvel foi utilizado como subscrição de capital social, independentemente do seu valor, de modo que a imunidade deve incidir.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

A hipótese dos autos, portanto, não se confunde com aquela examinada pelo Pretório Excelso, no qual parte do bem imóvel, além daquela utilizada na integralização do capital social, é destinada à reserva de ágio. Somente neste último caso é que se admite a cobrança de ITBI sobre o excesso.

Todavia, daí não se pode concluir que o magistrado a quo deveria ter declarado a não recepção das limitações tipificadas nos arts. 36, I, II e 37 do CTN, eis que tal pretensão não se coaduna com a via do mandado de segurança, que, como se sabe, não pode ser impetrado contra lei em tese.

Deveras, considerando que o pedido final é o de afastar a aplicação de parte do texto legal, sob a justificativa de ser inconstitucional/não ter sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, forçoso convir que o presente mandado de segurança se volta contra lei em tese, o que é vedado pela Súmula nº 266 do STF, senão vejamos:

Súmula nº 266, STF: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. (MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017).

Frisa-se à exaustão, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, não sendo meio processual idôneo para impugnar normas gerais e abstratas. É esta a lição do eminente ministro Alexandre de Moraes, senão vejamos:

“O mandado de segurança poderá ser repressivo de uma ilegalidade já cometida, ou preventivo quando o impetrante demonstrar justo receio de sofrer uma violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada.

Nesse caso, porém, sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão concreta que esteja pondo em risco o direito do impetrante, ou no dizer de Caio Tácito, 'atos preparatórios ou indícios razoáveis, a tendência de praticar atos, ou omitir-se a fazê-lo, de tal forma que, a conservar-se esse propósito, a lesão de direito se torne efetiva'”. (DE MORAES. Alexandre. Direito Constitucional. 32ª ed. 2016. Pág. 276).

Justamente por isso, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao enfrentar a questão referente ao caráter incondicional da imunidade tributária como parte da fundamentação da sentença, eis que os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de admitir que a inconstitucionalidade – ou não recepção – de dispositivo infraconstitucional seja aventada como causa de pedir (AgInt no MS 24.258/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018).

Não se há, pois, de cogitar em omissão da sentença apelada, eis que, de maneira eskorreita, limitou-se a declarar o direito líquido e certo da impetrante, exaurindo o objeto do writ, sendo absolutamente desnecessário e, até mesmo, inviável o acolhimento de pedido declaratório de não recepção dos dispositivos legais. Bem por isso, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

À luz do exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação cível e lhe nego provimento. Outrossim, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença. Deixo de fixar honorários recursais, visto que não arbitrados na sentença [1], por cuidar-se de mandado de segurança (art. 25, lei nº 12.016/2009 [2]). É como voto

21. Assim, o venerando acórdão viola norma constitucionais, bem como vai de encontro ao entendimento firmado por este Excelso STF, motivo pelo qual deve ser reformado.

V. MÉRITO – TEMA 796 STF

22. Inicialmente importante transcrever aqui o definido por Vossas Excelências no julgamento do Tema 796:

Tema 796 - Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

Há Repercussão?

Sim

Relator(a):

MIN. MARCO AURÉLIO

Leading Case:

[RE 796376](#)

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

Tese:

A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

23. Vale trazer à baila sobre o tema, que a Constituição da República enuncia o seguinte acerca da competência do Município para instituir o imposto sobre transmissão de bens imóveis - ITBI e da imunidade estabelecida, *in verbis*:

Art. 156. **Compete aos Municípios** instituir impostos sobre:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º - O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

24. Dessa forma, para que seja imune ao ITBI, portanto, a transmissão deve ter por finalidade a realização de capital social da pessoa jurídica adquirente. Como anota Aires F. Barreto², por meio de tal regramento, o legislador constitucional visou a facilitar a mobilização dos bens imóveis de seus sócios, estimulando assim a livre-iniciativa e o desenvolvimento econômico³.

25. Visando apenas para elucidar uma acertada interpretação sistemática, destaca-se que a regulamentação e demarcação dos limites da regra imunizante em análise é prevista na Lei Complementar que instituiu o Código Tributário Nacional, especificamente em seus artigos 36 e 37 do CTN, que assim dispõem:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, **o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:**

I – Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento do capital nela subscrito;

II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a quem foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se **caracterizada a atividade preponderante** referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

² BARRETO, Aires Fernandino. ITBI - Transmissão de Bens Imóveis da Empresa A para as Empresas B e C – Conceito de Atividades Preponderantes. In: *Revista Dialética de Direito Tributário* n.o 166. São Paulo: Dialética, jul. 2009, p. 161.

³ Cf. RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. In: Martins, Ives Gandra da Silva (coord.). *Comentários ao Código Tributário Nacional*. São Paulo: Saraiva, 2006, vol. 1, p. 308.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

V.1) Do Julgamento Pelo Supremo Tribunal Federal – Re 796.376 – Repercussão Geral – Correta Interpretação – do condicionamento da atividade preponderante também para a integralização de capital.

26. Como se vê, a hipótese de incidência da regra imunizante em exame toma como referência a receita operacional da pessoa jurídica adquirente, de sorte que, na análise de sua aplicação, o que prepondera não é o objeto social indicado no ato de constituição da interessada, mas sim a substância da atividade econômica por ela desempenhada nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição.

27. Nesse diapasão, nota-se facilmente que o art. 156 §2º inciso I da Carta Magna combinado com os arts. 36 e 37 do CTN de forma clara condicionam a incidência da imunidade, a qual NÃO PODE SER APLICADA DE FORMA INCONDICIONAL, como fez o r. acórdão recorrido.

28. Desse modo, o julgamento do RE 796.376 por este Excelso STF não pode ser interpretado como pretenderam os Eminentíssimos julgadores *a quo*.

29. Cumprido **repelir** a alegação de que o STF firmou entendimento no sentido de que as integralizações de bens imóveis ao capital de sociedades seriam imunes ao ITBI independentemente da atividade da empresa que recebe os imóveis, enquanto as transmissões de patrimônio imobiliário em decorrência de operações de fusão, cisão e incorporação estariam condicionadas à ausência de atividade preponderante imobiliária da sociedade adquirente / incorporadora, **pois não condiz com a verdade quando analisado o julgamento do Tema 796.**

30. Com efeito, tal entendimento foi ensaiado em *passant* pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento que fixou a tese (RE 796.376) sobre o limite da imunidade em atos de integralização, quando o Pretório Excelso, salvo melhor juízo, **apenas decidiu pela sujeição ao ITBI da diferença entre o valor do imóvel integralizado e o capital subscrito.**

31. **Obviamente a afirmação de imunidade incondicionada no caso de integralização do capital social resta equivocada, haja vista que o assunto SEQUER ESTAVA EM PAUTA, a qual se limitou ao Tem 796, com seguinte teor repita-se:**





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Tema 796 - Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

32. Dos debates e julgamento foi firmada a seguinte tese, novamente transcrita pela importância do assunto:

Tese Firmada:

A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

33. Vejam Excelências, que o assunto debatido e analisado por todos os Ministros foi EXCLUSIVAMENTE se a imunidade seria ou não aplicada sobre a diferença entre o valor da integralização e o valor real do bem (de avaliação).

34. Assim, um posicionamento de um Ministro acerca de tema que sequer estava *sub judice* não pode ser considerado entendimento do Supremo Tribunal, o qual permita alterar jurisprudência pacífica acerca de outro assunto (qual seja: a imunidade na integralização é ou não incondicional).

35. Diante disso, resta tranquila a afirmação que o julgamento do Tema 796 EM NADA ALTEROU O ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE DO ITBI QUANDO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA É CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA ATIVIDADE PREPONDERANTE, nos termos do art. 156, §2º, da CF/88 c.c. art. 37, §§ 1º e 2º, CTN.

V.2) Do Julgamento Pelo Supremo Tribunal Federal – Re 796.376 – Repercussão Geral – Correta Interpretação – da possibilidade de reavaliação do valor do imóvel objeto da integralização de capital.

36. Ao lado do que acima foi dito, importa destacar que **a imunidade** estabelecida no artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta da República **adstringe-se ao valor necessário à integralização do capital social**, pois o artigo 36 do Código Tributário Nacional faz menção de que a não-incidência (*rectius*, imunidade) limita-se ao capital subscrito, não sendo razoável sua concessão quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

37. Diante desse cenário, à luz do estatuído no art. 36 do CTN, caso o valor de mercado do imóvel integralizado supere o valor das cotas integralizadas, o ITBI incidirá sobre a parte excedente⁴.

38. Destaca-se novamente que o Excelso Pretório fixou a seguinte tese em repercussão geral (tema 796), *litteris*: “**A imunidade em relação ITBI**, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, **não alcança** o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

39. Analisando o que restou decidido pelo Excelso Pretório no tema 796, os Tribunais Pátrios têm se alinhado à posição adotada no ato administrativo objeto da impetração e tem se pronunciando no sentido do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve esse entendimento em decisões proferidas em 2022, senão vejamos:

APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI - Subscrição do capital social por meio da integralização de bem imóvel ao patrimônio - **Valor venal do imóvel superior ao valor nominal do capital social - Cobrança do imposto sobre a diferença do valor do bem que superar o capital subscrito – Imunidade constitucional (art. 156, § 2o, I, da CF) que não alcança o valor do bem que exceder o valor integralizado - Matéria decidida em sede de recursos repetitivos pelo C. STF (RE 796376) - Tema 796** - Fato gerador. Registro do título translativo da propriedade. Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo, contudo, correção monetária - Sentença reformada - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1001725-39.2021.8.26.0400; Relator (a): João Alberto Pizarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022) (g.n.)

Apelação. Mandado de Segurança. Imunidade Tributária (art. 156, § 2o, I da CF). Integralização de capital social mediante a incorporação de imóveis. Pretensão de afastamento da incidência de ITBI sobre eventual diferença entre o valor do bem imóvel declarado pelo contribuinte e o valor venal do bem imóvel avaliado pela prefeitura. Sentença denegatória a ser mantida. Incidência, na hipótese, do tema 796 do STF, a saber: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. E, quanto ao correto parâmetro de avaliação do bem, registre-se que o art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nessa esteira, como já assentado pela doutrina e jurisprudência, adota-se, tanto para o IPTU, como para o ITBI, o mesmo valor, considerando-se aquele que for maior entre o valor venal e o valor da transação

⁴ Forçoso ressaltar ter sido reconhecida pelo Excelso Pretório, no RE n.o 796376, a repercussão geral da discussão em torno da extensão da imunidade em tela.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

imobiliária, a fim de que não haja inobservância ao princípio da legalidade. **No caso dos autos, o valor venal do bem é maior do que o declarado pelo impetrante, motivo pelo qual é correta a cobrança fazendária relativa ao ITBI sobre o valor que excede a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município, conforme guias de fls. 32/34.** Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1003176-82.2021.8.26.0438; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 10/05/2022; Data de Registro: 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI sobre imóveis transmitidos para integralização de capital social – Município de Bebedouro – **Benefício constitucional previsto no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal que se restringe ao limite da integralização do capital subscrito – Incidência do ITBI sobre o valor venal dos imóveis que exceder o valor da integralização – Repercussão Geral - RE 796.376/SC, Tema 796/STF - Precedentes desta Corte** - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário da impetrante não providos. (TJSP; Apelação Cível 1001272-58.2021.8.26.0072; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. ART. 38 DO CTN. TERMO QUE SE REFERE AO VALOR DE MERCADO. ART. 270 DO CTM. **INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, QUE PERMITE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL À PESSOA JURÍDICA, A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL, PELO VALOR CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE BENS DA PESSOA FÍSICA, SEM A CONFIGURAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL. ART. 23, §1º, DA LEI Nº 9.249/95. AUSÊNCIA DE PREVISÃO SEMELHANTE NA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO ITBI. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO NA HIPÓTESE DE O VALOR DECLARADO NÃO CONDIZER COM O DE MERCADO.** ART. 148 DO CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ART. 156, II, §2º, I, DA CF. ART. 36, I, DO CTN. FINALIDADE DA NORMA DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, A GERAÇÃO DE EMPREGOS, A CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E AS MELHORIAS SOCIAIS. PROTEÇÃO QUE NÃO VAI ALÉM DO NECESSÁRIO À CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR VENAL DOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSA O CAPITAL. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 796376 (TEMA 796). HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0005948-74.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 05.04.2022)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS/ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL A CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA AO VALOR DA QUOTA SOCIETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. **Conforme entendimento consolidado no Tema n.º 796, do STF, a imunidade do ITBI sobre bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, prevista no artigo 156, § 2.º, inciso I, da Constituição Federal, está adstrita ao valor que se pretende integralizar ao capital social da empresa, persistindo a ocorrência do fato gerador do referido tributo sobre o valor que exceder a quota societária.** A integralização do capital social da empresa por meio da incorporação de bens imóveis, deve observar os ditames do artigo 1.245, do Código Civil, ocorrendo a transferência imobiliária que é o fato gerador do ITBI. (TJMS. Apelação Cível n. 0800360-19.2021.8.12.0045, Sidrolândia, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 27/04/2022, p: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDA O INTEGRALIZADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. **A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.** (TJMS. Apelação Cível n. 0800044-45.2020.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 19/04/2022, p: 25/04/2022)

40. Ainda resta lembrar que no julgamento do Tema 1113 levado à julgamento sob rito de repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, houve manifestação dos Ministros acerca da questão de avaliação (analisando artigo de lei infraconstitucional sobre o assunto), sem dúvidas, fazendo constar na ementa do julgamento a conclusão:

“(…) 6. Em face do princípio da boa fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

(…)

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

- a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
- b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente por ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio art. 148 do CTN);
- c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valores de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

41. Portanto, não resta dúvidas acerca da legitimidade de tributação da diferença entre o valor integralizado pelo imóvel transferido à pessoa jurídica e o valor de avaliação deste bem, como definido em repercussão geral.

V.3) Da impugnação específica do acórdão recorrido

42. Cumpre ainda impugnar de forma específica o acórdão recorrido, demonstrando claramente que a sua conclusão está em total dissonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao reconhecimento de uma imunidade incondicionada do IBTI na integralização de capital, bem como quanto ao suposto alargamento do texto constituição em sede de reconhecimento de imunidade tributária.

43. O Acórdão recorrido afirma os seguintes fundamentos e conclusões:

CONCLUSÃO	FUNDAMENTO	IMPUGNAÇÃO
1º o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.	o § 2º, inc. I, primeira parte, do art. 156, da Constituição Federal,	A norma jurídica que concede imunidade ou isenção deve ser interpretada de forma restritiva, de modo que, adotando-se a interpretação estrita da Constituição, conclui-se que a análise da atividade preponderante não se restringe às reorganizações societárias, tal como decidido pelo e. TJES, senão também à integralização de capital com conferência de bem imóvel pelo sócio.
2º A regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de	o § 2º, inc. I, primeira parte, do art. 156, da Constituição Federal,	O assunto acerca da diferença entre o valor da integralização de capital e o valor do bem integralizado já foi objeto do julgamento do Tema 796 no qual restou definida a incidência





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário.		do ITBI na diferença entre os valores. <i>"A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI."</i>
3ª uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável.	lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º,	Normas específicas de direito societário e contábil não podem interferir na competência tributária e nas regras matrizes de incidência de tributos definidos pelo artigo 156 I CF e art 32 do CTN, e tampouco na definição de imunidade tributária, assunto que somente pode ser tratado de forma geral por Lei Complementar - CTN.

44. Visto isso não há como sustentar os fundamentos do acórdão recorrido em face de julgamento já concluído pelo STF acerca do assunto em debate nestes autos.

VI. CONCLUSÃO:

45. Diante de todo o exposto, requer a Vossas Excelências seja o presente recurso extraordinário RECEBIDO, ADMITIDO e PROCESSADO, a fim de que, após remetido ao Excelso Supremo Tribunal Federal, venha o mesmo a ser INTEGRALMENTE PROVIDO, e, em consequência, REFORMADO o acórdão guerreado, denegando a segurança pretendida, de modo a manter incólume o ato administrativo questionado.

NESTES TERMOS, PEDEM DEFERIMENTO.
Vitória | ES | 02 | setembro | 2021.

LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE
Procuradora Municipal
OAB/ES n.º 10.673
Matrícula n.º 302261-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Ref. APELAÇÃO Nº: 5002479-81.2021.8.08.0021

RECORRENTE: Município de Guarapari/ES

RECORRIDA: Abreu Judice Participações LTDA

MUNICÍPIO DE GUARAPARI, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vêm, por seu procurador infra-assinado, perante Vossa Excelência, com amparo no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da CRFB/88, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

irresignado com o v. acórdão de **ID 5330855**, publicado em 21/07/2023, com ciência eletrônica em 31/07/2023, prolatado na Apelação nº **5002479-81.2021.8.08.0021**, proferido pela Egrégia 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na forma do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, fundamentado nas razões anexas, pelo que, admitido e processado regularmente, requer seja o presente recurso submetido a julgamento perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

NESTES TERMOS, PEDEM DEFERIMENTO.

Vitória | ES | 14 | setembro | 2023.

LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE
Procuradora Municipal
OAB/ES n.º 10.673
Matrícula n.º 302261-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ref. APELAÇÃO Nº: 5002479-81.2021.8.08.0021

RECORRENTE: Município de Guarapari/ES

RECORRIDA: Abreu Judice Participações LTDA

R A Z Õ E S R E C U R S A I S

COLEDA TURMA
EXCELENTÍSSIMOS MINISTROS,

I. ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL

I.1) Tempestividade e preparo

1. O presente recurso alcança os requisitos de forma e de tempestividade em sua totalidade, obedecendo exatamente às condições determinadas no art. 1.029 e seguintes CPC.
2. Considerando as publicações, o prazo de 15 dias em dobro findar-se-á na data de hoje – 14/09/2023 conforme verifica-se no próprio PJE, senão vejamos:

ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA Expedição eletrônica (21/07/2023 13:23:33) O sistema registrou ciência em 21/07/2023 23:59:59 Prazo: 15 dias	22/08/2023 23:59:59 (para manifestação)	Sim
Auditor (113641) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Representante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo Expedição eletrônica (21/07/2023 13:23:33) Gestor MPES MHI registrou ciência em 24/07/2023 13:52:09 Prazo: 30 dias	05/09/2023 23:59:59 (para manifestação)	Sim
Auditor (113640) MUNICIPIO DE GUARAPARI Representante: Procuradoria do Município de Guarapari Expedição eletrônica (21/07/2023 13:23:33) O sistema registrou ciência em 21/07/2023 23:59:59 Prazo: 30 dias	14/09/2023 23:59:59 (para manifestação)	Não

3. Destaca-se que houve suspensão de prazos processuais em razão de feriados de 11 de agosto e 07 e 08 de setembro de 2023, como verifica-se da resolução do TJES. Portanto, protocolizado até a data, **o presente recurso é tempestivo.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Ato Normativo 220/2022

Categoria: Atos Normativos
Data de disponibilização: Quinta, 10 de Novembro de 2022
Número da edição: 6728
Replicações: [Clique aqui para ver detalhes](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PJES
RUA DESEMBARGADOR HOMEROMAFRA,60 - Bairro ENSEADA DO SUÁ - CEP 29050906 - Vitória - ES - www.tjes.jus.br

MINUTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA GERAL

ATO NORMATIVO Nº 220/2022

O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a existência de feriados decretados em lei,

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário deve estabelecer com antecedência o calendário de funcionamento das repartições que lhe são subordinadas,

RESOLVE:

Art. 1º. Publicar a relação de feriados do ano de **2023**, conforme **Anexo Único**, de abrangência em todo o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo dos feriados de cada Município sede de Comarca e/ou Juízo.

Art. 2º. A data de *Corpus Christi*, dia **08 de junho de 2023** (quinta-feira), será considerada ponto facultativo nas unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo localizadas em Municípios onde não houver lei específica que já a considere feriado.

Parágrafo único. A data de **09 de junho de 2023** (sexta-feira) será considerada ponto facultativo em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Art. 3º. Os dias não trabalhados nos pontos facultativos devem ser compensados ao longo dos dias úteis seguintes, por meio da extensão da jornada de trabalho em 01 (uma) hora, cabendo às chefias imediatas a atribuição de observar o rigoroso cumprimento da carga horária.

Art. 4º. Os efeitos deste Ato não se aplicam às Serventias Extrajudiciais.

Publique-se.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira
Presidente

ANEXO ÚNICO – FERIADOS DO ANO DE 2023

(...)

Agosto

11 (sexta-feira) – Dia do Advogado (art. 141, "d", da Lei Complementar Estadual nº 234/2002)

Setembro

07 (quinta-feira) – Independência do Brasil (art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002)

08 (sexta-feira) – Ponto Facultativo (e Feriado de Nossa Senhora da Vitória no Município de Vitória/ES, conforme art. 1º da Lei Municipal nº 1.732/1967)

4. Como sabido, o Município possui prerrogativa de pagamento ao final do processo de eventuais custas de sua responsabilidade, estando, portanto, preenchido requisito do preparo recursal.

I.2) Cabimento do recurso especial e prequestionamento

5. Conforme já asseverado, o presente recurso extraordinário tem como fundamento o artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal¹, e viola normas

¹ **Constituição Federal.** Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

previstas na legislação infraconstitucional, e ainda altera entendimento adotado pelo próprio Colendo Superior Tribunal, como restará demonstrado.

6. Como adiante especificamente demonstrado, o acórdão recorrido viola frontalmente os artigos 35, 36, inciso I, 37 §§ 1º a 3º e art. 148 do CTN, artigos estes que foram analisados expressamente pelo acórdão ora recorrido (fls. 01, 05, 06 do voto constante no ID 5330855).

7. Dessa forma, se delimita como objeto da discussão deste recurso a negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais:

➤ Artigo 37 §§ 1º a 3º do CTN.

8. Acerca do pré-questionamento, tem-se que no voto proferido os MM. Desembargadores analisaram os dispositivos de lei *sub judice*, de forma expressa, o que facilmente percebe-se ao logo das fundamentações.

I.3) Da desnecessidade de reanálise fático-probatória – não incidência do óbice do Enunciado da Súmula 7 deste e. STJ

9. Além do cumprimento dos pressupostos citados nos tópicos acima, importante destacar, ainda, que a matéria tratada no presente recurso especial não demanda o reexame fático probatório a ensejar a aplicação da Súmula 7 deste E. STJ, uma vez que as balizas fáticas na qual se funda o direito do Município Recorrente foram devidamente reconhecidas pelo v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do E. TJES.

10. Pois bem.

11. O que se pretende com a interposição do presente recurso é o reconhecimento da existência de condições para configuração da imunidade tributária prevista no art. 156 § 2º, inciso I da Constituição Federal, consoante determina o art. 37 caput e parágrafos do CTN, não podendo se afirmar que se trata de uma imunidade incondicional, como fez o Tribunal *a quo*, em razão das previsões legais dos dispositivos supra citados e violados.

12. Para isso, basta a simples leitura do texto legal dos dispositivos, bem como dos inúmeros julgados que acompanham o correto entendimento deste Eg. Superior Tribunal de Justiça para se verificar que se trata de matéria eminentemente de direito neste *mandamus*, bem como que o E. Tribunal *a quo* chegou à conclusão jurídica diversa do entendimento do Eg. STJ.

recorrida: a) **contrariar** tratado ou **lei federal**, ou **negar-lhes vigência**; (...) c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

II. DA RELEVÂNCIA DO TEMA

13. Resta por fim ainda essencial destacar a clara existência de relevância das questões debatidas no caso, que ultrapassam os limites do simples interesse das partes.

14. Em paralela análise com a repercussão geral exigida nos recursos extraordinários, destaca-se que no Leading Case [RE 796376](#) a repercussão geral foi admitida sob o seguinte fundamento em situação semelhante ao presente caso (incidência do ITBI na integralização de capital social):

Plenário Virtual
PRONUNCIAMENTO

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO ITBI IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:

Submeto a Vossa Excelência o tema versado no Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, para exame da oportunidade de inclusão da matéria no sistema eletrônico da repercussão geral.

O processo revela mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Município, consistente na negativa de emissão da guia para recolhimento do Imposto de Transmissão Inter Vivos ITBI, referente aos imóveis integralizados ao capital da empresa, com a imunidade total prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. A autoridade administrativa justificou a negativa no fato de o valor total dos imóveis exceder em muito o capital integralizado. O Juízo implementou a liminar, confirmando-a na sentença, para reconhecer a imunidade e determinar que a autoridade coatora se absteresse de cobrar o referido tributo.

A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, à unanimidade, deu provimento à apelação do Município e à remessa necessária, para indeferir a ordem. Observou restringir-se a imunidade estabelecida no artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta da República ao valor do imóvel suficiente à integralização do capital social. Afirmou que a intenção do constituinte foi facilitar a criação de novas sociedades e a movimentação dos bens correspondentes ao respectivo capital. Consignou haver, no artigo 36 do Código Tributário Nacional, menção de que a não incidência estaria restrita ao capital subscrito, não sendo razoável a concessão de imunidade quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente. Assentou que a empresa não atua no comércio de imóveis, inexistindo razão para a incorporação de bens de quantia superior ao valor nominal das cotas. Concluiu pela imunidade apenas do valor referente à parcela dos imóveis necessária à integralização do capital social, incidindo o ITBI sobre a parte que exceder.

O acórdão impugnado encontra-se assim resumido:

TRIBUTÁRIO - ITBI - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, INCISO II, DA CF/1988) - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS RESPECTIVOS - IMUNIDADE QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL E DAS COTAS INTEGRALIZADAS COM IMÓVEIS - EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

A imunidade tributária prevista na primeira parte do inciso II do § 2º do art. 156, da Constituição Federal de 1988 impede a incidência do imposto de transmissão de bens imóveis "inter vivos" somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Vale dizer, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá incidência do tributo.

Os embargos declaratórios foram desprovidos.

No extraordinário, protocolado com alegada base nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a empresa argui ofensa aos artigos 1º, 5º, incisos II e XXXVI, 37, cabeça, 156, § 2º, inciso II, e 170, inciso IV, do Diploma Maior. Sustenta não haver, na Carta Federal, qualquer limitação no tocante à observância da imunidade do ITBI na realização de capital, não podendo o Fisco nem o Poder Judiciário restringir a incidência, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Segundo aduz, a sociedade empresária foi regularmente formalizada, consubstanciando ato jurídico perfeito, e esclarece que outro Município do mesmo Estado tem reconhecido a imunidade sem qualquer ressalva, o que gera insegurança jurídica.

Ressalta que a Carta de 1988, ante o princípio da livre iniciativa, previu a mencionada imunidade com o objetivo de facilitar a entrada de pessoas naturais e jurídicas no mercado, permitindo a integralização de capital social não só mediante a disponibilidade de dinheiro, mas também por meio de transmissão de bens imóveis sem a incidência de imposto. Sublinha ser a maioria do empresariado brasileiro representado por pequenas e médias empresas que não possuem capital elevado. Aponta a incoerência de possibilitar um benefício fiscal sem que seja viável a grande parte dos cidadãos. Defende que o dinamismo das relações societárias não deve encontrar obstáculos no Estado, salvo nos casos descritos em lei, pois ele depende do mercado para arrecadar tributos e, assim, desenvolver políticas públicas.

*Salienta haver cumprido os requisitos estabelecidos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional para o reconhecimento da aludida imunidade, a qual deve ser considerada uma vedação absoluta ao poder de tributar. Diz da impossibilidade de o Tribunal de origem presumir que a intenção da empresa não é a integralização do capital e enfatiza ser o contrato social uma relação entre particulares, na qual predomina a autonomia da vontade. **Esclarece que, de acordo com o ato constitutivo, a diferença entre o valor dos imóveis e a quantia integralizada será contabilizada como reserva de capital.***

Sob o ângulo da repercussão geral, afirma ultrapassar o tema o interesse subjetivo das partes, mostrando-se relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico. Assinala que a matéria é de interesse das sociedades empresárias constituídas e aponta a necessidade de definir-se o alcance da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta da República.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

O extraordinário foi admitido na origem.

Atendeu-se aos pressupostos gerais de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal. O preparo encontra-se devidamente comprovado.

2. Ante o disposto no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assentou que a imunidade incide somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. O preceito constitucional prevê:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

[...]

[...]

I não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesse caso, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

[...]

Eis tema a reclamar o crivo do Supremo, definindo-se o alcance da norma, ou seja, cabe ao guarda maior da Lei das Leis elucidar se o dispositivo contempla limitação à imunidade considerado o Imposto de Transmissão Inter Vivos.

3. Pronuncio-me no sentido de ter como configurada a repercussão geral. Uma vez admitida, colham o parecer da Procuradoria Geral da República, visando a apreciação da controvérsia e, portanto, o julgamento do recurso extraordinário.

4. À Assessoria, para acompanhar a tramitação do incidente, inclusive quanto aos processos que, no Gabinete, versem a mesma matéria.

5. Publiquem.

Brasília residência , 11 de fevereiro de 2015, às 10h15.

Ministro MARCO AURÉLIO

Relator

15. Nesse interim, facilmente se percebe a importância do tema, não só para os empresários que precisam ter certeza jurídica para empreenderem no país, mas também para os Municípios que possuem competência tributária para exigir tributo ITBI sobre referida integralização de capital, de modo que a completa interpretação do tema é condição *sine qua non* para harmonizar as relações entre contribuintes e Municípios de todo Brasil.

16. Cumpre destacar que o Poder Judiciário brasileiro está repleto de ações acerca do referido tema, nas quais inúmeros Municípios discutem a matéria, inclusive com vários posicionamentos díspares, o que restará demonstrado.

17. Por óbvio que o tema objeto do presente ultrapassa em muito um interesse subjetivo das partes, devendo ser admitida sua análise por este Eg. Superior Tribunal, a fim de pacificar as relações contribuintes X Municípios brasileiros.

IV. BREVE SÍNTESE DOS AUTOS:

18. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora recorrida, na qual pretende ver declarada a imunidade absoluta e incondicional quanto ao ITBI incidente sobre a diferença entre o valor da transferência declarada na integralização de capital, e o valor de avaliação do Município. Vejamos o pedido formulado:

Seja reconhecido o direito líquido e certo de a impetrante fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre transmissão do apartamento no 201, do Edifício Praia de





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

*Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, neste município, **incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sem qualquer reserva de valor à conta de capital ou de ágio, prevalecendo o valor constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 220.000,00 – duzentos e vinte mil reais)**, e como tal integralizado como capital da sociedade empresaria em 220 – duzentos e vinte – mil cotas, **afastando, definitivamente e por completo, a exação de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos)**, em 28.05.2021, ou qualquer outra a ser apurada, ilegalmente, sobre a diferença entre o valor do imóvel acima destacado, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00 – oitocentos e oitenta mil reais);*

19. Por conseguinte, sem qualquer apuração de fatos, pois trata-se de mandado de segurança, foi proferida sentença a qual foi integralmente mantida pelo acórdão ora guerreado, negando vigência ao artigo 37 caput do CTN e demais normas dos parágrafo 1º ao 3º, sob os seguintes fundamentos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002479-81.2021.8.08.0021
APELANTE: ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como sumariamente relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por Abreu Júdice Participações Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente (id 2503672) que, no mandado de segurança impetrado em face do Secretário da Fazenda do Município de Guarapari, concedeu a segurança para “declarar a incidência de imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio a impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 43.799, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 200.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 220 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00)”.

Em sua peça recursal (id 2503693), a sociedade empresária aduz, em síntese, haver omissão quanto ao pedido “b”, da petição inicial, pelo qual requer seja “definitivamente reconhecido que a imunidade a que faz jus a Impetrante não encontra limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, uma vez incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF (transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital)”. Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame do seu mérito, em conjunto com a análise da remessa necessária. Isso porque





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

se trata de sentença concessiva de segurança, estando sujeita, pois, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição, por imposição do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresarial, ora apelante, por meio do qual pretende seja reconhecido o seu direito líquido e certo de fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre transmissão do apartamento nº 201,

do Edifício Praia de Bacutia, situado na Avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

A discussão a respeito da incidência, ou não, da imunidade tributária decorre do fato de o Município de Guarapari, em processo administrativo, ter avaliado o bem no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), ao passo que a quantia informada pelo contribuinte, nos termos da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice, foi de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Nesse contexto, o Fisco Municipal entendeu que haveria a incidência do ITBI sobre a diferença equivalente a R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), visto que o Supremo Tribunal Federal teria entendimento consolidado no sentido de que a imunidade não alcançaria o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Sobre o tema, isto é, acerca do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, não é demais rememorar que, ao distribuir a competência impositiva entre os entes tributantes, nossa Carta Maior outorgou aos Municípios a competência para instituir o imposto sobre a “transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição” (art. 156, inc. II), demarcando, com isso, os comportamentos suscetíveis de serem colhidos pelo legislador como hipótese de incidência do aludido tributo.

Acontece que a própria Carta Magna, no mesmo dispositivo, estabelece a não incidência do ITBI em certas operações societárias, instituindo hipóteses de imunidade objetiva, que visam estimular a capitalização e o crescimento das empresas.

Deveras, o inciso I do §2º do citado artigo 156, preconiza que:

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Da redação do supratranscrito dispositivo legal, é possível constatar que sobre a transmissão de bens ou direitos imobiliários incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, seja (i) para a integralização do capital social ou (ii) em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não incide o ITBI, desde que, “nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

O texto constitucional, portanto, impõe uma condicionante para a não incidência do tributo, consistente no fato de que a atividade empresarial preponderante da pessoa jurídica adquirente não se enquadre como a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Neste particular, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Relator(a):





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, Repercussão Geral – Mérito Dje-210, Divulg 24-08-2020 Public 25-08-2020), definiu que a imunidade referente ao ITBI para integralização de bens imóveis no capital social da empresa não é absoluta, sendo limitada ao valor do capital fixado, de sorte que montante excedente está sujeito à tributação.

Todavia, ao fixar a tese de repercussão geral, o Pretório Excelso não fez nenhuma ressalva quanto à diferenciação da atividade empresarial para fins de excluir aquelas que atuem no ramo imobiliário.

Pelo contrário, o que se observa do voto condutor do acórdão, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, é que o tema atinente à atividade preponderante da pessoa jurídica foi expressamente enfrentado pela c. Corte, segundo a qual “as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica”.

Como se sabe, dentro da sistemática de precedentes judiciais adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, a doutrina especializada nos ensina que são as razões de decidir dos precedentes que operam a vinculação - “extraí-se da ratio decidendi, por indução, uma regra geral que pode ser aplicada a outras situações semelhantes. Da solução de um caso concreto (particular) extraí-se uma regra de direito que pode ser generalizada” (In Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil – 11 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v.2, p. 460). Seguindo essa linha de inteligência, não há como deixar de reconhecer que a maioria do STF, naquela ocasião, entendeu pela necessidade de se distinguir os significados de “incorporação de bens em realização de capital” e “incorporação de bens ao patrimônio”, expressões utilizadas, respectivamente, na primeira e segunda oração do artigo do Texto Maior. Para os ministros, a primeira situação o n s t i t u i m u n i d a d e incondicionada, pois somente no segundo caso é que a imunidade se limita às hipóteses em que a sociedade incorporadora do patrimônio imobiliário não desenvolva atividade preponderantemente imobiliária.

A simples leitura da íntegra do acórdão é suficiente para constatar que a ratio decidendi do precedente em questão está calcada na imprescindível distinção entre as duas hipóteses de imunidade previstas no art. 156, §2º, I, da CF, eis que o voto vencedor é enfático neste ponto, dedicando vários parágrafos se chegar a tal conclusão. Não se trata, pois, de mero obter dictum, mas sim da interpretação dada pelo Pretório Excelso ao referido dispositivo constitucional.

Aliás, vale registrar que não houve declaração implícita de inconstitucionalidade do art. 37 do CTN, mas tão somente interpretação conforme a Constituição, de modo a preservar validade da lei, indicando a leitura da norma que melhor se coaduna com a Carta Magna. Destarte, de acordo com o novo posicionamento do STF, é preciso compreender que a exceção estipulada no art. 37 do CTN alcança apenas as hipóteses previstas no inciso II do art. 36 daquele diploma, eis que as situações constantes em seu inciso I são imunes de ITBI independentemente de qualquer condicionante.

Logo, é de se concluir que, muito embora não conste na redação da tese de repercussão geral, o Supremo de fato decidiu expressamente, no julgamento do Tema nº 796, que a imunidade prevista na primeira parte do art. 156, §2º, inciso I, da CF/88 – transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital – é incondicionada, porquanto independe da atividade empresarial exercida pela adquirente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Ademais, conforme bem explicitado pela sentença, a regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário.

Até mesmo porque a lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, ao dispor sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável, senão vejamos:

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital. (g.n)

Conquanto a supracitada lei verse sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas, fato é que o seu teor serve para demonstrar a inoccorrência de ato ilícito por parte da sociedade empresária e de seu sócio. Pelo contrário, a legislação pátria lhes confere a faculdade de optar por esta forma de integralização do capital social, de modo que a conduta do Município apelado, além de afrontar dispositivo constitucional, acaba por indevidamente frustrar essa opção do contribuinte legalmente permitida. É dizer, todo o imóvel foi utilizado como subscrição de capital social, independentemente do seu valor, de modo que a imunidade deve incidir.

A hipótese dos autos, portanto, não se confunde com aquela examinada pelo Pretório Excelso, no qual parte do bem imóvel, além daquela utilizada na integralização do capital social, é destinada à reserva de ágio. Somente neste último caso é que se admite a cobrança de ITBI sobre o excesso.

Todavia, daí não se pode concluir que o magistrado a quo deveria ter declarado a não recepção das limitações tipificadas nos arts. 36, I, II e 37 do CTN, eis que tal pretensão não se coaduna com a via do mandado de segurança, que, como se sabe, não pode ser impetrado contra lei em tese.

Deveras, considerando que o pedido final é o de afastar a aplicação de parte do texto legal, sob a justificativa de ser inconstitucional/não ter sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, forçoso convir que o presente mandado de segurança se volta contra lei em tese, o que é vedado pela Súmula nº 266 do STF, senão vejamos:

Súmula nº 266, STF: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

ação direta de inconstitucionalidade. (MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017).

Frisa-se à exaustão, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, não sendo meio processual idôneo para impugnar normas gerais e abstratas. É esta a lição do eminente ministro Alexandre de Moraes, senão vejamos:

“O mandado de segurança poderá ser repressivo de uma ilegalidade já cometida, ou preventivo quando o impetrante demonstrar justo receio de sofrer uma violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada. Nesse caso, porém, sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão concreta que esteja pondo em risco o direito do impetrante, ou no dizer de Caio Tácito, 'atos preparatórios ou indícios razoáveis, a tendência de praticar atos, ou omitir-se a fazê-lo, de tal forma que, a conservar-se esse propósito, a lesão de direito se torne efetiva'”. (DE MORAES. Alexandre. Direito Constitucional. 32ª ed. 2016. Pág. 276).

Justamente por isso, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao enfrentar a questão referente ao caráter incondicional da imunidade tributária como parte da fundamentação da sentença, eis que os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de admitir que a inconstitucionalidade – ou não recepção – de dispositivo infraconstitucional seja aventada como causa de pedir (AgInt no MS 24.258/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018).

Não se há, pois, de cogitar em omissão da sentença apelada, eis que, de maneira escorreita, limitou-se a declarar o direito líquido e certo da impetrante, exaurindo o objeto do writ, sendo absolutamente desnecessário e, até mesmo, inviável o acolhimento de pedido declaratório de não recepção dos dispositivos legais. Bem por isso, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

À luz do exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação cível e lhe nego provimento. Outrossim, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença. Deixo de fixar honorários recursais, visto que não arbitrados na sentença [1], por cuidar-se de mandado de segurança (art. 25, lei nº 12.016/2009 [2]). É como voto

20. Assim, o venerando acórdão viola normas infraconstitucionais, bem como vai de encontro ao entendimento firmado por este Egrégio STJ e ainda gera dissonância nos entendimentos dos Tribunais pátrios em casos idênticos, motivo pelo qual deve ser reformado.

V. MÉRITO

V.1) Da ofensa a Lei federal e ao entendimento pacífico do STJ

21. Inicialmente importante transcrever aqui o recente entendimento definido por Vossas Excelências nos seguintes julgamentos:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E [APELAÇÃO CÍVEL](#). [AÇÃO DECLARATÓRIA](#). [ITBI](#). [IMUNIDADE TRIBUTÁRIA](#). [INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL](#). SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELO REQUERIDO. ARTIGO 373, INCISO II, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. A imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Está disciplinada no artigo 156 da Constituição Federal e nos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional. 2. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição, nos termos do § 2º do artigo 37 do Código Tributário Nacional. 3. Na espécie, o ente público municipal promoveu a fiscalização para fins de confirmação da isenção do ITBI açambarcou lapso temporal fora dos limites previstos no texto constitucional, sendo que a prova pericial comprovou que a ausência de atividade predominantemente de transações imobiliárias, revelando a impropriedade da exação tributária. 4. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: Toca ao requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao requerido, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem descumprir desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas. 5. No caso concreto, o alegado ato simulado de planejamento tributário por parte da requerente não ultrapassou sequer o campo das meras conjecturas, sem nenhum lastro probatório a justificar a assertiva de simulação agitada pelo requerido. 6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do [artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil](#). REMESSA NECESSÁRIA E [APELAÇÃO CÍVEL](#) CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; DGJ-AC 5156556-04.2016.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 04/08/2022; DJEGO 09/08/2022; Pág. 3654).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.

1. O acórdão embargado consignou: "Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para a concessão da imunidade do ITBI, prevista nos arts. 156, II, § 2º, da CF e 37 do CTN. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: No caso dos autos, embora a impetrante tenha postulado o reconhecimento da imunidade em virtude da incorporação do bem imóvel ao capital social, inexistem receitas no período de verificação da preponderância, fato que impossibilita a verificação dos requisitos previstos na legislação em vigor. A recorrente não demonstrou à fiscalização o exercício de atividade empresarial no período de verificação, pelo contrário, o que se verifica é que a própria empresa reconhece a ausência de atividade empresária. Nesse sentido, posicionou-se a municipalidade, ao indeferir o pedido de imunidade tributária, fundamentando sua decisão no art. 116 do CTN e no § 7º do art. 214 da Lei Municipal nº 3.560/14 (fl. 2660, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em [Recurso Especial](#) (Súmula nº 7/STJ)". 2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

no acórdão embargado. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em [Recurso Especial](#), mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. [Embargos de Declaração rejeitados](#). (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.999.766; Proc. 2021/0322244-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/09/2022; DJE 26/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCABIMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 7/STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo em [Recurso Especial](#), confirmando a inadmissão do [Recurso Especial](#) por incidência da Súmula nº 7/STJ e entendendo pelo enfoque eminentemente constitucional dado ao julgado. 2. A controvérsia que se pretende ver resolvida nestes autos cinge-se a saber se a pessoa jurídica, recém-constituída, mesmo sem exercer atividade econômica, pode se beneficiar de imunidade de ITBI, em relação ao patrimônio imobiliário transmitido à agravante o qual se encontra gravado com usufruto vitalício em benefício de terceiros. **3. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia sob o enfoque eminentemente constitucional, ao asseverar, expressamente, que, à luz do disposto no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, é imprescindível o efetivo exercício das atividades empresariais e a obtenção de receitas patrimoniais para o gozo da imunidade relativa ao ITBI, e "não se vislumbra atividade econômica típica a sociedade", o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em [Recurso Especial](#), sob pena de usurpação da competência do STF.** 4. Não cabe analisar a tese defendida no Recurso Especial, de que o Fisco deveria aguardar 3 anos após a integralização dos bens imóveis para verificar a atividade preponderante da empresa para fins de aplicação do art. 36 e 37 do CTN. Inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que não se vislumbra atividade econômica típica da sociedade. Incide o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Precedentes no mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.682.791/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.667.625/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 12.11.2020; AgInt no AREsp 1.336.834/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; AgInt no AREsp 780.620/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22.11.2016 e AgInt no [RESP](#) 1.533.249/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 13.9.2017. 6. [Agravo Interno não provido](#). (STJ; AgInt-AREsp 1.768.274; Proc. 2020/0255338-9; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 26/04/2022; DJE 27/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, INCISO II, § 2º, INCISO I, DA CF E 37 DO CTN. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, DECIDIU AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. LEI LOCAL. ART. 214, §7º, DA LEI MUNICIPAL 3.560/2014. SÚMULA Nº 280/STF.

1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para a concessão da imunidade do ITBI, prevista nos arts. 156, II, § 2º, da CF e 37 do CTN. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "No caso dos autos, embora a impetrante tenha postulado o reconhecimento da imunidade em virtude da incorporação do bem imóvel ao capital social, inexistem receitas no período de verificação da preponderância, fato que impossibilita a verificação dos requisitos previstos na legislação em vigor. A recorrente não demonstrou à fiscalização o exercício de atividade empresarial no período de verificação, pelo contrário, o que se verifica é que a própria empresa reconhece a ausência de atividade empresária. Nesse sentido, posicionou-se a municipalidade, ao indeferir o pedido de imunidade tributária, fundamentando sua decisão no art. 116 do CTN e no § 7º do art. 214 da Lei Municipal nº 3.560/14" (fl. 2660, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 5. Ademais, a análise sobre a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 tem caráter eminentemente constitucional, sendo defeso o exame pelo STJ, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso. 6. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu a demanda com base no art. 214, §7º, da Lei Municipal 3.560/2014. O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local, consoante o Verbete Sumular 280/STF. 7. [Agravo Interno não provido](#). (STJ; AgInt-AREsp 1.999.766; Proc. 2021/0322244-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/06/2022)

22. Vale trazer à baila sobre o tema, que a Constituição da República enuncia o seguinte acerca da competência do Município para instituir o imposto sobre transmissão de bens imóveis - ITBI e da imunidade estabelecida, *in verbis*:

Art. 156. **Compete aos Municípios** instituir impostos sobre:

(...)

II - **transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis**, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º - O imposto previsto no inciso II:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

23. Dessa forma, para que seja imune ao ITBI, portanto, a transmissão deve ter por finalidade a realização de capital social da pessoa jurídica adquirente. Como anota Aires F. Barreto², por meio de tal regramento, o legislador constitucional visou a facilitar a mobilização dos bens imóveis de seus sócios, estimulando assim a livre-iniciativa e o desenvolvimento econômico³.

24. Visando apenas elucidar uma acertada interpretação sistemática, destaca-se que a regulamentação e demarcação dos limites da regra imunizante em análise é prevista na Lei Complementar que instituiu o Código Tributário Nacional, especificamente em seus artigos 36 e 37 do CTN, que assim dispõem:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, **o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:**

I – Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento do capital nela subscrito;

II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a quem foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se **caracterizada a atividade preponderante** referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

² BARRETO, Aires Fernandino. ITBI - Transmissão de Bens Imóveis da Empresa A para as Empresas B e C – Conceito de Atividades Preponderantes. In: *Revista Dialética de Direito Tributário* n.o 166. São Paulo: Dialética, jul. 2009, p. 161.

³ Cf. RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. In: Martins, Ives Gandra da Silva (coord.). *Comentários ao Código Tributário Nacional*. São Paulo: Saraiva, 2006, vol. 1, p. 308.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

V.2) Do Entendimento do STJ – Correta Interpretação – do condicionamento da atividade preponderante também para a integralização de capital – ausência de alteração do entendimento pelo STF.

25. Como se vê, a hipótese de incidência da regra imunizante em exame toma como referência a receita operacional da pessoa jurídica adquirente, de sorte que, na análise de sua aplicação, o que prepondera não é o objeto social indicado no ato de constituição da interessada, mas sim a substância da atividade econômica por ela desempenhada nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição.

26. Nesse diapasão, nota-se facilmente que os artigos 36 e 37 do CTN de forma clara condicionam a incidência da imunidade prevista no art. 156 §2º inciso I da Carta Magna, a qual NÃO PODE SER APLICADA DE FORMA INCONDICIONAL, como fez o r. acórdão recorrido.

27. Cumpre **repelir** a alegação de que o STF firmou entendimento no sentido de que as integralizações de bens imóveis ao capital de sociedades seriam imunes ao ITBI independentemente da atividade da empresa que recebe os imóveis, enquanto as transmissões de patrimônio imobiliário em decorrência de operações de fusão, cisão e incorporação estariam condicionadas à ausência de atividade preponderante imobiliária da sociedade adquirente / incorporadora, **pois não condiz com a verdade quando analisado o julgamento do Tema 796.**

28. Com efeito, tal entendimento foi ensaiado em *passant* pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento que fixou a tese (RE 796.376) sobre o limite da imunidade em atos de integralização, quando o Pretório Excelso, salvo melhor juízo, **apenas decidiu pela sujeição ao ITBI da diferença entre o valor do imóvel integralizado e o capital subscrito.**

29. Obviamente a afirmação de imunidade incondicionada no caso de integralização do capital social resta equivocada, haja vista que o assunto SEQUER ESTAVA EM PAUTA do Supremo, a qual se limitou ao Tema 796, com seguinte teor repita-se:

Tema 796 - Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

30. Dos debates e julgamento foi firmada a seguinte tese, novamente transcrita pela importância do assunto:

Tese Firmada:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

31. Vejam Excelências, que o assunto debatido e analisado por todos os Ministros foi EXCLUSIVAMENTE se a imunidade seria ou não aplicada sobre a diferença entre o valor da integralização e o valor real do bem (de avaliação).

32. Assim, um posicionamento de um Ministro acerca de tema que sequer estava *sub judice* não pode ser considerado entendimento do Supremo Tribunal, o qual permita alterar jurisprudência pacífica acerca de outro assunto (qual seja: a imunidade na integralização é ou não incondicional).

33. Ademais, o próprio STF distinguiu o assunto agora debatido neste recurso, e aquele analisado quando do julgamento do Tema 796 do STF, tratando-se de questões distintas.

34. Para isso, basta a simples leitura do texto constitucional e da interpretação já delineada por este Excelso STF no ARE 1316381 para se concluir pelo desalinhamento do acórdão recorrido com a análise deste Tribunal, vez que não houve, no julgamento do tema 796, alteração do entendimento quanto a condição acerca da atividade da empresa. Cita-se:

“[...] a pretensa aplicação do **RE 796.376-RG** ao caso em exame não merece acolhida. **No julgamento do referido paradigma, o Plenário do STF decidiu que, na integralização do capital social por meio de bens imóveis, a diferença de valor que superar o capital subscrito a ser integralizado será tributada pelo ITBI.** Diferentemente, na hipótese destes autos, a Corte de origem concluiu pela inaplicabilidade da regra imunitória em razão de controvérsia acerca da atividade preponderante exercida pela empresa, aferida mediante análise de sua receita operacional. Portanto, a matéria discutida no RE 796.376-RG não guarda semelhança com a questão posta no presente recurso. [...]. (ARE 1316381 ED- segundos, Relator(a): Min. Roberto Barroso, j. 16/08/2021)

35. Diante disso, os Tribunais regionais pátrios pacificaram o entendimento de que na integralização de capital somente haverá imunidade se preenchidos os requisitos e condicionantes do art. 37 do CTN, *in litteris*:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

A Lei de Mandado de Segurança confere ao magistrado a possibilidade de conceder liminar em mandado de segurança, desde que se façam presentes o relevante fundamento e que do ato impugnado possa resultar ineficácia do provimento final. Art. 7º, III, da Lei nº





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

12.016/2009.. Concedida sob condição resolutive, a imunidade do ITBI sobre incorporação de imóveis ao capital social de sociedade empresária somente prevalece quando comprovada a preponderância da atividade econômica nos 3 (três) anos seguintes à incorporação do imóvel no capital social da pessoa jurídica, na forma estabelecida pelo art. 3º da Lei Municipal nº 5.492/1988 c/c art. 36 e 37 do Código Tributário Nacional. Agravo de instrumento desprovido. (TJMG; AI 1336367-61.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 27/01/2022; DJEMG 28/01/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 37 DO CTN. ATIVIDADE PREPONDERANTE. TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS. REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do artigo 37 do Código Tributário Nacional, o imposto de ITBI pode ser cobrado apenas após o período de análise da preponderância da atividade da empresa. 2. Demonstrados os requisitos necessário ao pedido liminar, o seu deferimento é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJMT; AI 1016727-73.2019.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Maria Erotides Kneip; Julg 21/03/2022; DJMT 04/04/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 37 DO CTN. ATIVIDADE PREPONDERANTE. TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS. REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do artigo 37 do Código Tributário Nacional, o imposto de ITBI pode ser cobrado apenas após o período de análise da preponderância da atividade da empresa. 2. Demonstrados os requisitos necessário ao pedido liminar, o seu deferimento é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJMT; AI 1016727-73.2019.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Maria Erotides Kneip; Julg 21/03/2022; DJMT 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTE À DATA DE AQUISIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §3º, DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

Saliente-se que para que se caracterize uma atividade como preponderante, excetuando o direito à imunidade do ITBI, tanto o art. 37, § 1º e 2º, do Código Tributário Nacional quanto o art. 6º, IV, § 3º, da Lei Complementar Municipal 197/89 trazem dois critérios: Um material, que consiste em como saber se a atividade é preponderante, e um temporal, consistente no quando se deve verificar a atividade. Por outro lado, a exoneração do tributo é condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e desde que comprovada a preponderância de negócios imobiliários. Apelo desprovido. (TJMT; AC 1007660-39.2019.8.11.0015; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Maria Erotides Kneip; Julg 24/01/2022; DJMT 03/02/2022) Ver ementas semelhantes





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA IMUNIDADE SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL PARA O FIM DE INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL DA AGRAVANTE. VERIFICAÇÃO DE IMUNIDADE QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. Inadequação da via eleita. Conjunto probatório que não demonstra, de plano, que a **atividade preponderante da pessoa jurídica se enquadra nas exceções que autorizariam a não incidência do tributo. Art. 37 do CTN.** Penhora. Pretensão de substituição por imóvel. Recusa da Fazenda Pública. Possibilidade. Necessidade de se observar a ordem legal. Art. 11 da LEF e art. 835 do CPC. **Recurso conhecido e não provido.** (TJPR; AgInstr 0025568-31.2022.8.16.0000; Maringá; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cesar Zeni; Julg. 22/08/2022; DJPR 24/08/2022)

36. Assim, resta tranquila a afirmação que o julgamento do Tema 796 EM NADA ALTEROU O ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE DO ITBI QUANDO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA É CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA ATIVIDADE PREPONDERANTE, nos termos do art. 37, §§ 1º e 2º, CTN.

V.3) Do Julgamento Pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 1113 – Repetitivo – Correta Interpretação – da possibilidade de revisão do valor de avaliação para base de cálculo do ITBI.

37. No julgamento do Tema 1113 levado à julgamento sob rito de repetitivo neste Eg. Superior Tribunal de Justiça, houve manifestação dos Ministros acerca da questão de avaliação (analisando artigo de lei infraconstitucional sobre o assunto), sem dúvidas, fazendo constar na ementa do julgamento a conclusão:

“(…) 6. Em face do princípio da boa fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

(…)

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses:

- a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
- b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente por ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio art. 148 do CTN);





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valores de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

38. Diante desse cenário, à luz do estatuído no art. 36 e 37 do CTN, caso o valor de mercado do imóvel integralizado supere o valor das cotas integralizadas, o ITBI incidirá sobre a parte excedente⁴, o que vem sendo reconhecido pelos Tribunais Pátrios, *in verbis*:

APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI - Subscrição do capital social por meio da integralização de bem imóvel ao patrimônio - **Valor venal do imóvel superior ao valor nominal do capital social - Cobrança do imposto sobre a diferença do valor do bem que superar o capital subscrito – Imunidade constitucional (art. 156, § 2o, I, da CF) que não alcança o valor do bem que exceder o valor integralizado - Matéria decidida em sede de recursos repetitivos pelo C. STF (RE 796376) - Tema 796** - Fato gerador. Registro do título translativo da propriedade. Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo, contudo, correção monetária - Sentença reformada - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1001725-39.2021.8.26.0400; Relator (a): João Alberto Pizarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022) (g.n.)

Apelação. Mandado de Segurança. Imunidade Tributária (art. 156, § 2o, I da CF). Integralização de capital social mediante a incorporação de imóveis. Pretensão de afastamento da incidência de ITBI sobre eventual diferença entre o valor do bem imóvel declarado pelo contribuinte e o valor venal do bem imóvel avaliado pela prefeitura. Sentença denegatória a ser mantida. Incidência, na hipótese, do tema 796 do STF, a saber: "A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". E, quanto ao correto parâmetro de avaliação do bem, registre-se que o art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nessa esteira, como já assentado pela doutrina e jurisprudência, adota-se, tanto para o IPTU, como para o ITBI, o mesmo valor, considerando-se aquele que for maior entre o valor venal e o valor da transação imobiliária, a fim de que não haja inobservância ao princípio da legalidade. **No caso dos autos, o valor venal do bem é maior do que o declarado pelo impetrante, motivo pelo qual é correta a cobrança fazendária relativa ao ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município, conforme guias de fls. 32/34.** Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1003176-82.2021.8.26.0438; Relator (a): Beatriz Braga;

⁴ Forçoso ressaltar ter sido reconhecida pelo Excelso Pretório, no RE n.o 796376, a repercussão geral da discussão em torno da extensão da imunidade em tela.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 10/05/2022; Data de Registro: 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI sobre imóveis transmitidos para integralização de capital social – Município de Bebedouro – **Benefício constitucional previsto no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal que se restringe ao limite da integralização do capital subscrito – Incidência do ITBI sobre o valor venal dos imóveis que exceder o valor da integralização – Repercussão Geral - RE 796.376/SC, Tema 796/STF - Precedentes desta Corte** - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário da impetrante não providos. (TJSP; Apelação Cível 1001272-58.2021.8.26.0072; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS/ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL A CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA AO VALOR DA QUOTA SOCIETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. **Conforme entendimento consolidado no Tema n.º 796, do STF, a imunidade do ITBI sobre bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, prevista no artigo 156, § 2.º, inciso I, da Constituição Federal, está adstrita ao valor que se pretende integralizar ao capital social da empresa, persistindo a ocorrência do fato gerador do referido tributo sobre o valor que exceder a quota societária.** A integralização do capital social da empresa por meio da incorporação de bens imóveis, deve observar os ditames do artigo 1.245, do Código Civil, ocorrendo a transferência imobiliária que é o fato gerador do ITBI. (TJMS. Apelação Cível n. 0800360-19.2021.8.12.0045, Sidrolândia, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 27/04/2022, p: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDA O INTEGRALIZADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. **A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.** (TJMS. Apelação Cível n. 0800044-45.2020.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 19/04/2022, p: 25/04/2022)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

39. Portanto, não resta dúvidas acerca da legitimidade de tributação da diferença entre o valor integralizado pelo imóvel transferido à pessoa jurídica e o valor de avaliação deste bem, como definido em repercussão geral.

V.3) Da interpretação da norma da Lei 9.249/95 artigo 23, § 1º

40. A título de complementação da discussão, um dos fundamentos do acórdão utilizados para permitir que fosse utilizado o valor de origem no imóvel, ao invés do valor de mercado (avaliação), foi o art. 23, § 1º da Lei 9.249/95.

41. Entretanto, a legislação do ITBI não possui nenhuma previsão semelhante quando trata da regra matriz de incidência, não podendo ser aplicada na situação em discussão nestes autos, como vem decidindo os Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. ART. 38 DO CTN. TERMO QUE SE REFERE AO VALOR DE MERCADO. ART. 270 DO CTM. **INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, QUE PERMITE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL À PESSOA JURÍDICA, A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL, PELO VALOR CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE BENS DA PESSOA FÍSICA, SEM A CONFIGURAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL. ART. 23, §1º, DA LEI Nº 9.249/95. AUSÊNCIA DE PREVISÃO SEMELHANTE NA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO ITBI. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO NA HIPÓTESE DE O VALOR DECLARADO NÃO CONDIZER COM O DE MERCADO.** ART. 148 DO CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ART. 156, II, §2º, I, DA CF. ART. 36, I, DO CTN. FINALIDADE DA NORMA DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, A GERAÇÃO DE EMPREGOS, A CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E AS MELHORIAS SOCIAIS. PROTEÇÃO QUE NÃO VAI ALÉM DO NECESSÁRIO À CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR VENAL DOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSA O CAPITAL. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 796376 (TEMA 796). HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Cível - 0005948-74.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 05.04.2022)

V.4) Da impugnação específica do acórdão recorrido

42. Cumpre ainda impugnar de forma específica o acórdão recorrido, demonstrando claramente que a sua conclusão está em total dissonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento de suposta inaplicabilidade das condicionantes do art. 37 do CTN para imunidade do IBTI na integralização de capital social.

43. O Acórdão recorrido afirma os seguintes fundamentos e conclusões:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

CONCLUSÃO	FUNDAMENTO	IMPUGNAÇÃO
1º o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.	o § 2º, inc. I, primeira parte, do art. 156, da Constituição Federal.	A norma jurídica que concede imunidade ou isenção deve ser interpretada de forma restritiva, de modo que, adotando-se a interpretação estrita da Constituição, conclui-se que a análise da atividade preponderante não se restringe às reorganizações societárias, tal como decidido pelo e. TJES, senão também à integralização de capital com conferência de bem imóvel pelo sócio.
2º A regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário.	o § 2º, inc. I, primeira parte, do art. 156, da Constituição Federal,	O assunto acerca da diferença entre o valor da integralização de capital e o valor do bem integralizado já foi objeto do julgamento do Tema 796 no qual restou definida a incidência do ITBI na diferença entre os valores. <i>“A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.”</i>
3º autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável.	lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º,	Normas específicas de direito societário e contábil não podem interferir na competência tributária e nas regras matrizes de incidência de tributos definidos pelo artigo 156 I CF e art 32 do CTN, e tampouco na definição de imunidade tributária, assunto que somente pode ser tratado de forma geral por Lei Complementar - CTN.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

44. Visto isso não há como sustentar os fundamentos do acórdão recorrido em face de julgamento já concluído pelo STJ acerca do assunto em debate nestes autos.

VI. CONCLUSÃO:

45. Diante de todo o exposto, requer a Vossas Excelências seja o presente recurso especial RECEBIDO, ADMITIDO e PROCESSADO, a fim de que, após remetido ao Excelso Superior Tribunal de Justiça, venha o mesmo a ser INTEGRALMENTE PROVIDO, e, em consequência, REFORMADO o acórdão guerreado, denegando a segurança pretendida, de modo a manter incólume o ato administrativo questionado.

46.

NESTES TERMOS, PEDEM DEFERIMENTO.
Vitória | ES | 14 | setembro | 2023.

LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE
Procuradora Municipal
OAB/ES n.º 10.673
Matrícula n.º 302261-7

